

LISTE DES ABREVIATIONS

Abréviation	Signification
Art.	Article
C. civ.	Code civil
C. civ. guin.	Code civil guinéen
Cass.	Cour de cassation
Cass. civ.	Cour de cassation, chambre civile
Cass. civ. 1re	Cour de cassation, première chambre civile
Cass. soc.	Cour de cassation, chambre sociale
CJ	Cour de justice
CP	Code pénal
CPC	Code de procédure civile
C. trav.	Code du travail
Dr.	Droit
Éd.	Édition
LGDJ	Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence
n°	Numéro
op. cit.	opere citato (ouvrage cité précédemment)
p.	Page
pp.	Pages
PUF	Presses Universitaires de France
s.	Suivant
s.	Suivants
TGI	Tribunal de grande instance
TPI	Tribunal de première instance
V°	Voir

RESUME

La liberté contractuelle constitue l'un des principes fondamentaux du droit des obligations. Elle permet aux parties de conclure librement des conventions et d'en déterminer le contenu conformément à leurs intérêts. Toutefois, cette liberté n'a jamais été absolue. Elle s'inscrit dans un cadre juridique marqué par l'intervention croissante du juge, tant lors de la formation du contrat que durant son exécution.

Le présent mémoire a pour objet d'analyser les atteintes portées à la liberté contractuelle par le juge à travers ses pouvoirs d'interprétation, de qualification, de requalification et de maintien du contrat. Dans un premier temps, l'étude met en lumière le rôle du juge lors de la formation du contrat. À travers le pouvoir interprétatif, le juge est amené à rechercher le sens véritable des stipulations contractuelles, en recourant à différentes méthodes, notamment la méthode subjective, la méthode objective et la méthode *in favorem*. Par ailleurs, le pouvoir de qualification et de requalification permet au juge de restituer aux faits leur véritable nature juridique, entraînant soit une majoration des obligations contractuelles, soit une réduction de la portée de l'acte.

Dans un second temps, le mémoire s'intéresse au maintien du contrat par le juge, même lorsque celui-ci est susceptible d'être anéanti. Il apparaît que le juge peut refuser l'annulation ou la résolution du contrat afin de préserver la stabilité des relations contractuelles. L'étude met également en évidence l'intervention judiciaire en cas d'imprévision, à travers la révision du contrat lorsque l'exécution devient excessivement onéreuse pour l'une des parties et qu'aucun accord n'a pu être trouvé.

En définitive, cette recherche montre que la liberté contractuelle demeure un principe fondamental, mais qu'elle est désormais encadrée par un pouvoir judiciaire renforcé. Le juge apparaît ainsi comme un véritable régulateur des relations contractuelles, chargé de concilier l'autonomie de la volonté avec les exigences de justice, d'équité et de sécurité juridique.

Mots-clés : liberté contractuelle, pouvoir du juge, interprétation du contrat, requalification, maintien du contrat, imprévision.

ABSTRACT

Contractual freedom is one of the fundamental principles of the law of obligations. It allows parties to freely enter into agreements and determine their content according to their respective interests. However, this freedom has never been absolute. It operates within a legal framework increasingly shaped by judicial intervention, both at the stage of contract formation and during its performance.

This dissertation aims to analyze the limitations imposed on contractual freedom by the judge through the powers of interpretation, qualification, requalification, and maintenance of the contract. Firstly, the study examines the judge's role in the formation of the contract. Through interpretative powers, judges seek to clarify the meaning of contractual clauses by applying various methods, including subjective interpretation, objective interpretation, and the in favorem principle. In addition, the power of qualification and requalification enables the judge to determine the true legal nature of the agreement, which may result in either an increase in contractual obligations or a reduction of the legal effects of the act.

Secondly, the research focuses on the judicial maintenance of contracts that are otherwise liable to annulment or termination. It highlights the judge's ability to refuse annulment or resolution in order to preserve contractual stability. Particular attention is given to judicial intervention in cases of hardship (imprévision), where the judge may revise the contract when performance becomes excessively onerous and no agreement can be reached between the parties.

Ultimately, this study demonstrates that contractual freedom remains a fundamental principle, but one that is now subject to enhanced judicial oversight. The judge thus emerges as a key regulator of contractual relations, tasked with balancing the autonomy of the parties with the requirements of fairness, equity, and legal certainty.

Keywords: *contractual freedom, judicial power, contract interpretation, requalification, contract maintenance, hardship.*

SOMMAIRE

INTRODUCTION	1
PARTIE 1: L'ENCADREMENT LEGISLATIF DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE	5
Chapitre I : Les atteintes conventionnelles à la liberté contractuelle.....	7
Section 1 : Les clauses limitant la liberté de contracter ou de ne pas contracter	7
Section 2 : Les clauses limitant la liberté de choisir son cocontractant, le contenu et la forme du contrat.....	14
Chapitre II : Les disposition d'ordre public et la liberté contractuelle	19
Section 1 : L'ordre public, une limite à la liberté contractuelle	19
Section 2 : La sanction découlant de la violation des dispositions d'ordre public..	23
PARTIE 2: L'ENCADREMENT DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE INITIE PAR LE JUGE.....	30
Chapitre I : L'encadrement à la liberté contractuelle initie par le juge lors de la formation du contrat.....	32
Section 1 : Atteintes à travers le pouvoir interprétatif du juge.....	32
Section 2 : Atteintes à travers le pouvoir de qualification et requalification par le juge	40
Chapitre II : Les atteintes à la liberté contractuelle liées au maintien du contrat par le juge.....	49
Section 1 : Le maintien d'un contrat susceptible d'être anéanti.....	49
Section 2 : L'atteinte à la liberté contractuelle à travers la révision pour imprévision	56
CONCLUSION GENERALE.....	65

INTRODUCTION

Nul besoin d'être un spécialiste en droit pour se rendre compte de l'importance des contrats dans la vie quotidienne des personnes.

Le simple acte usuel de tous les jours peut se percevoir à travers le prisme du contrat. Acheter le pain, se vêtir, se distraire, ... la liste est longue¹. Ce contrat, dans sa formation, en passant par son exécution jusqu'à son anéantissement est gouverné par le principe de l'autonomie de la volonté. C'est la volonté qui est au début et à la fin du contrat, elle y apparaît comme une reine. Ce principe a plusieurs dérivés, notamment l'effet relatif du contrat², la force obligatoire et l'intangibilité³, la bonne foi⁴ et le principe de la liberté contractuelle⁵.

En effet, le contrat ne produit d'effets qu'à l'égard des parties, par principe. Cette règle exclut les tiers du champ contractuel. Ils ne doivent ni tirer avantage du contrat, ni contribuer à sa violation⁶. Toutefois, ce principe est aujourd'hui remis en cause, puisque l'inexécution du contrat causant préjudice à un tiers, le fonde à obtenir des dommages et intérêts. Les parties peuvent le poursuivre aussi lorsqu'il se porte complice de la violation du contrat. Telle est la physionomie du principe de l'effet relatif du contrat.

A côté, nous avons la force obligatoire, selon laquelle, seule la volonté commune peut défaire ce qu'elle a fait⁷.

Le principe de la bonne foi, quant à lui, renvoie à la loyauté dans la conclusion et dans l'exécution des actes juridiques⁸. L'article 1035 du code civil guinéen dispose dans ce contexte que : « *Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette*

¹ Adeline VILLAIN, *l'immixtion du juge dans le contrat, mémoire de master droit privé général 2012-2013*, p1.

² Art 1095 du c.civ.g.

³ Art 1091 et 1092 du c.civ.g.

⁴ Art 1035 du c.civ.g.

⁵ Art 1034 al.2 et 3 du c.civ.g.

⁶ Art.1095 al. 1, 2 et 3 du C.civ.g.

⁷ Art.1091 et suiv. du C.civ.g.

⁸ Jean-Luc Albert et ol. *Sous la direction de Serge Guinchard et Terry Debard*, 26^e édition 2018-2019, p.141.

disposition est d'ordre public. » Autrement dit, la loyauté et la sincérité doivent être la devise des parties à toutes les étapes du contrat.⁹

Il convient à ce stade de notre étude, d'apporter des précisions terminologiques. Pour ce faire, nous définirons d'abord séparément « la liberté » et « contractuel » en passant par une définition commune. Ensuite, nous dirons ce qu'il faut entendre par contrat et les limites à la liberté contractuelle. Ainsi, couramment, la liberté signifie qu'on peut faire tout ce qu'on veut sans être inquiété. C'est l'« *état d'une personne qui n'est pas soumise à la servitude ; possibilité d'agir, de penser, de s'exprimer selon ses propres choix* »¹⁰. C'est dans cette optique que le grand philosophe Jean Jacques ROUSSEAU affirma que : « *l'homme est naturellement bon et qu'il faut le laisser faire des choses* »¹¹. La notion contractuelle, quant à elle, renvoie à ce qui est « stipulé par un contrat »¹², ce qui a un rapport avec le contrat. Ainsi, littéralement, la liberté contractuelle signifie que les parties ont droit de concevoir leur contrat, d'y exprimer à leur guise ce qu'elles veulent sans être inquiétées par une force extérieure, par un pouvoir extérieur. Juridiquement, la liberté contractuelle est un « *principe général de droit, directement issu de la théorie de l'autonomie de la volonté, selon lequel les sujets de droit sont libres de conclure ou non un contrat et de déterminer leurs obligations réciproques* »¹³. C'est la même définition consacrée au principe de la liberté contractuelle par le code civil guinéen du 04 juillet 2019 par son article 1034 qui dispose : « *Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat...* ».

Ce principe a trois volets. Le premier est la liberté de contracter ou de ne pas contracter. Cela s'explique par le fait que, dans un contrat, tout le monde est libre de donner ou non son consentement. Un consentement vicié ne peut produire des effets. Le deuxième concerne le choix du cocontractant : « *une partie doit être libre de choisir le contractant avec lequel elle va se lier. Le contrat étant un acte de prévision, les parties doivent*

⁹ De la négociation à la rupture du contrat.

¹⁰ Sabine Delacherie-Henry, Cécile Nief et Vanessa Vandevoorde, Larousse. Dictionnaire de français, p. 805

¹¹ J.J.ROUSSEAU, *contrat social, Essai*, 1762.

¹² Le Robert, anon., édition millésime 2014, p. 494.

¹³ Jean-Luc Albert et ol. Sous la direction de Serge Guinchard et Terry Debard op. Cit, p.640.

pouvoir choisir leur cocontractant, en fonction de critères qu'elles vont prédéfinir, comme la solvabilité ou la réputation du partenaire¹⁴ ». Le dernier est celui qui permet aux parties de déterminer le contenu et la forme de leur contrat. Dans le contrat les parties peuvent insérer les clauses qu'elles veulent pour l'exécution du contrat et choisir la forme de leur contrat sans aucune imposition. Cependant, cette liberté se trouve aujourd'hui battue en brèche.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1034 alinéa premier du code civil guinéen, « *le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations* ». Avec cette définition il n'y a plus de différence entre un contrat et une convention car la convention crée des obligations, les modifie et les éteint, ce qui est le cas maintenant d'un contrat en droit guinéen des contrats. Cependant, son homologue sénégalais l'a défini comme un accord de volontés générateur d'obligations¹⁵. Partant de cette définition, nous pouvons en déduire qu'au Sénégal, le contrat se distingue de la convention. Pour notre part, les deux mots sont employables indifféremment, puisque dorénavant, au même titre que la convention, les parties peuvent renégocier leur contrat, le modifier, l'éteindre (clause résolutoire) et le transmettre à travers la cession de contrat. Nous pouvons à présent définir les limites à la liberté contractuelle comme les atteintes qu'on lui fait, qu'elles soient légales, conventionnelles et judiciaire.

En effet, dans le cadre de notre étude, ce sont ces limites qui vont nous servir d'aiguillon, tout en écartant les études pointues sur la liberté contractuelle en droit public. En revanche, rien n'empêche de prendre quelques illustrations en la matière.

Le principe de la liberté contractuelle ne figurait pas dans l'ancien code civil guinéen du 16 février 1983. Il a fallu attendre la grande réforme du droit des contrats en France à travers l'ordonnance du 10 février 2016 dont le législateur guinéen s'est inspiré pour que l'on consacre *expressis verbis*¹⁶ la liberté contractuelle dans l'article 1034 alinéa 2 du nouveau code civil du 04 juillet 2019. Cependant, bien que la liberté contractuelle ne fût

¹⁴ M. LATINA, « Contrat », Dalloz, 2013, cité par Mamadou Cellou SOUARE, *La rupture du contrat guinéen*, Mémoire, Université Général Lansana Conté, 2019-2020, p.10.

¹⁵ Art.40 COCC du Sénégal.

¹⁶ *Expressément dans le code civil.*

pas explicitement consacrée par l'ancien code civil guinéen, on pouvait la constater tacitement à travers des dispositions relatives au contrat¹⁷.

Le contrat étant un outil juridique indispensable à la vie des individus¹⁸ et caractérisé par le principe de la liberté contractuelle, l'encadrement de cette liberté a une importance capitale. Il permet de protéger l'ordre public social et économique, et l'intérêt des parties faibles dans le contrat, donc créer un équilibre entre l'intérêt général et ceux des parties, même si certaines parties parviennent à faire conclure des contrats déséquilibrés à leur profit. C'est la loi qui permet tout de même aux parties de déroger au principe par convention. Tel est l'intérêt théorique de ce sujet. Avec ce thème, nous comprendrons également que, d'un point de vue pratique, le juge, qui ne devait jadis pas s'immiscer dans le périmètre contractuel, s'est arrogé le pouvoir de porter atteinte à la liberté contractuelle. Certains de ses pouvoirs sont légalisés, tels que l'interprétation et la révision. Il peut tout de même refuser de donner des effets à la volonté des parties, notamment à travers les clauses qu'il peut juger excessivement onéreuses pour l'autre partie et le pouvoir pour lui de maintenir le contrat même malgré la volonté positive des parties dans ce sens. Il nous paraît pertinent et justifier, en ce sens que la rupture du contrat ne présente parfois aucune utilité.

La liberté contractuelle ne veut pas dire qu'on libre de faire tout ce qu'on veut dans nos relations contractuelles. Elle est limitée par la loi, pour protéger l'intérêt général et l'intérêt du plus faible dans une relation contractuelle. Dès lors, dans cette étude, il s'agit de savoir de quelle manière est-il possible de porter atteinte à la liberté contractuelle ?

On est libre d'être lié ou pas à un contrat, de déterminer son contenu et même d'y mettre fin. Cependant, cette liberté est astreinte par le garde-fou que la loi elle-même a mis en place (première partie) et par l'imperium du juge (deuxième partie).

¹⁷ Art 637 et suivants de l'ancien code civil guinéen.

¹⁸ Op. Cit. Mamadou Cellou SQUARE, mémoire de master, 2019-2020.

PARTIE 1: L'ENCADREMENT LEGISLATIF DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE

C'est la loi qui défend ; c'est la loi qui autorise. La liberté est un droit naturel, donc on la découvre. Ce principe de la liberté a pour prolongement celui de la liberté contractuelle, qui veut dire qu'on est libre de contracter ou de ne pas contracter, de déterminer le contenu et la forme que l'on veut donner à notre convention. Ce principe phare du droit des contrats, d'origine naturelle, est aujourd'hui de droit positif de nombreux États, notamment la France¹⁹ et la Guinée²⁰. Il est strictement encadré par la loi et c'est pourquoi sa violation entraîne des conséquences graves. Ainsi, les codes civils français et guinéens, prévoient qu'on ne peut déroger par des conventions aux dispositions d'ordre public et les mêmes textes permettent aux parties de circonscrire leur liberté contractuelle par des stipulations.

Ainsi, le législateur guinéen a prévu des dispositions supplétives et impératives. Les premières peuvent subir des dérogations par convention particulière (chapitre I). Quant aux secondes, les parties ne peuvent les écarter en prévoyant d'autres clauses compte tenu de leur caractère d'ordre public ²¹(chapitre II)

¹⁹ Art. 1102 du c.civ.fr.

²⁰ Art. 1034 du c.civ.gn

²¹ Art 12 c. civ. g.

Chapitre I : Les atteintes conventionnelles à la liberté contractuelle

Le contrat, est l'affaire des parties. C'est leur volonté qui y règne. Il s'agit du principe de l'autonomie de la volonté dont provient celui de la liberté contractuelle. Si les parties sont libres de définir leur rapport contractuel, de faire tout ce qu'elles veulent, il va s'en dire qu'elles ont l'aval de la loi de porter elle-même atteinte à cette liberté à travers des stipulations restrictives. Notamment, les parties peuvent insérer dans leur contrat des clauses attentatoires à la liberté de contracter ou de ne pas contracter (section 1), de choisir son cocontractant, le contenu et la forme son contrat (section 2).

Section 1 : Les clauses limitant la liberté de contracter ou de ne pas contracter

Les parties dans leurs relations contractuelles peuvent librement insérer des clauses qui portent atteinte à la liberté contractuelle de l'une d'entre elles. Ces clauses sont très nombreuses. Elles varient d'un contrat à un autre et parfois en fonction des domaines. C'est pourquoi, dans les contrats de travail, nous retrouvons fréquemment des clauses de non concurrence (paragraphe 1). Dans les contrats de travail et de mariage, nous rencontrons aussi la clause de non-convol (paragraphe 2).

Ces clauses ont été choisies pour faire l'objet de notre étude par ce qu'elles sont couramment rencontrées au sein de la société guinéenne.

Paragraphe 1 : La clause de non concurrence

La clause de non-concurrence est une clause insérée dans un contrat de travail aux fins d'éviter qu'à la fin de la relation du travail entre salarié et son employeur, le salarié ne concurrence son ancien employeur²². En outre, la clause de non-concurrence est celle par laquelle le salarié s'interdit lors de son départ de l'entreprise et pendant un certain temps par la suite, d'exercer certaines activités susceptibles de nuire à son ancien employeur²³. Cette clause est soumise à un régime juridique très cadré (A). Après l'étude de ce régime nous aborderons le lien qui existe entre cette clause et la liberté contractuelle(A).

²² Art 121.8 du c. du travail guinéen

²³ Me DJUMA ETIENNE Galilée, la clause de non-concurrence à la liberté contractuelle.

A- Le régime juridique de la clause de non-concurrence

Selon l'art. 121.8 du c. du travail « *le travailleur doit toute son activité professionnelle à l'employeur. Sauf dérogation stipulée au contrat de travail.*

Toutefois, il lui est loisible de son temps toute activité non susceptible de concurrencer l'employeur ou de nuire à la bonne exécution des services convenues. Est nulle de plein droit toute clause d'un contrat de travail portant une interdiction pour le travailleur d'exercer une activité quelconque à l'expiration du contrat. Sauf dans le cas où la rupture est le fait du travailleur ou résulte d'une faute lourde de sa part. Toutefois, dans ce cas, l'interdiction ne peut ne peut dépasser un an et ne s'appliquer que dans un rayon de trente(30) kilomètre ».

Il ressort de cette disposition quelques conditions pour la validation d'une clause de non-concurrence :

- La clause doit être écrite, elle doit être mentionnée dans le contrat de travail, l'écriture de la clause est essentielle pour assurer sa validité, sa clarté et pour garantir la sécurité des parties impliquées.
- Il faut que la rupture du contrat soit le fait de l'employé ou la cause de du licenciement soit une faute lourde de la part de l'employé, malgré quelle est prévue, pour qu'elle soit appliquée il faut que la faute vienne de l'employé. Cette condition protège l'employé des griffes de son employeur.
- L'interdiction doit se limiter à une année, toutefois, ce délai peut être renouveler avec le consentement du salarié²⁴ et dans l'espace de trente (30) kilomètre, cette limitation est essentielle pour préserver la liberté d'entreprendre du salarié et protéger la clientèle de l'ancien employeur.
- La clause doit comporter obligatoirement une contrepartie financière de nature salariale²⁵, versée à l'employé, la contrepartie financière est la contrepartie de l'engagement pris par l'employé de respecter la clause. Elle garantit un équilibre entre les droits et obligations des parties.

Toutes clauses de non-concurrence doivent respecter ces conditions à défaut elles seront nulles et nul effet.

²⁴ Arrêt N°21-12.006 du 13 septembre 2023. C. Cass.

²⁵ Art 2 de l'avenant n° 39 du 15 juin 2016 Relatif à la clause de non-concurrence

B- La clause de non-concurrence face à la liberté contractuelle

Comme nous venons de le constater pertinemment précédemment, le législateur guinéen a adopté d'une part la liberté contractuelle²⁶, principe selon lequel toute personne est libre de contracter ou de ne pas contracter et dès lors que la décision de contracter est prise, c'est avec le cocontractant de son choix. De l'autre part, le même législateur insère la clause de non concurrence²⁷ qui stipule que le salarié en fin contrat ne puisse pas concurrencer son ancien employeur en contractant chez un de ses concurrents. Par ailleurs, si dans le premier cas une personne était libre de contracter avec le cocontractant de son choix, le salarié en fin contrat ne jouirait pas, dans le second cas, de cette liberté. Il est soumis, de ce fait, à une clause de non-concurrence qui l'empêcherait de contracter en toute quiétude chez d'autres employeurs concurrents de son ancien employeur. Cependant, nous sommes d'avis qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence d'adoption de ces deux notions à la fois. Le législateur aurait voulu adopter un principe et son exception. De facto, le principe est dans une certaine façon « la liberté contractuelle » et l'exception en est « la clause de non-concurrence ». C'est pourquoi, tout individu est libre de contracter avec la personne de son choix et dans les conditions voulues par lui sauf s'il était précédemment soumis à une clause de non-concurrence dans un contrat précédemment conclu par lui, qui l'empêcherait de conclure un nouveau contrat en toute quiétude. En outre, dans le but fort ultime de protéger les entreprises et par-dessus tout, les employeurs, le législateur met sur pieds un principe et son exception, tant et si bien que les individus, jouissant certes d'une liberté contractuelle, ne puissent porter atteinte aux intérêts de leurs anciens employeurs.

Par conséquent, bien que les individus jouissent de la liberté de contracter avec les personnes de leur choix et dans les activités de leur choix, le législateur fait, par l'adaptation de la clause de non-concurrence, restriction à ceux-ci pourvu qu'ils ne puissent pas notablement porter préjudice aux intérêts légitimes de leurs employeurs lors de leur départ des entreprises.

En revanche, à une époque de plus grande mobilité des salariés, la clause de non concurrence est une entrave considérable quand on entend poursuivre sa carrière dans le

²⁶ Art. 1034 du c.civ.gn

²⁷ Art. 121.8 du c. du travail

même secteur. Cette clause contraint l'employé de contracter avec qui il veut et où il veut, car les conditions de la clause l'impose.

Pour finir, nous pouvons en déduire que la clause de non-concurrence est une limite à la liberté contractuelle plus précisément à la liberté de travail du salarié.

Paragraphe 2 : La clause de non-convol

A travers la clause de non-convol, on peut interdire à une partie de contracter mariage. C'est la clause de célibat (A). Également, elle permet aux parties d'interdire à une partie de se remarier. Il s'agit là de la clause de viduité (B).

A- Clause de célibat

Selon le principe de la liberté matrimoniale, tout individu est libre de se marier ou de ne pas se marier. Ce principe était considéré *«comme une composante de la liberté individuelle protégé par les articles 2 t 4 de le DDHC de 1789²⁸»*, puis désormais il est considéré *« comme une liberté personnelle²⁹ »*.

En effet il s'agit d'une liberté publique et fondamentale. Elle comprend trois aspects, la liberté de se marier, la liberté de ne pas se marier et la liberté de choisir son cocontractant. Au regard de liberté de se marier, on ne peut de quelque manière que ce soit empêcher une personne à se marier. Quant à la liberté de ne pas se marier, aucune législation ne peut obliger une personne à s'engager dans le lien du mariage.

Toutefois, au regard de la sécurité des personnes, le législateur a autorisé à poser certaines limites à la liberté matrimoniale³⁰. Les parties dans un contrat peuvent également dans certaines mesures poser des limites à la liberté matrimoniale par la voie conventionnelle, en stipulant une clause de célibat. En effet, la clause de célibat est une clause figurant dans un acte juridique et par laquelle les droits que cet acte juridique confère à une personne est subordonnés à la condition qu'elle demeure célibataire³¹.

En principe cette clause est réputée non écrite dans les actes à titre onéreux notamment le contrat de travail. Cependant, la clause de célibat peut être valable si elle remplit les conditions posées par la jurisprudence : il faut que la clause soit envisagée *«dans les cas exceptionnels où les nécessités de la fonction l'exigent impérieusement³²»*. Par exemple,

²⁸ Le conseil constitutionnel, décision 93-325 DC du 13 août 1993.

^{29 29} Le conseil constitutionnel, décision 2003-484 DC du 20 novembre 2003

³⁰ www.editions.ellipeses.fr

³¹ Source anonyme

³² AP.19 mai 1978 ; cass. Soc 7 février 1968

en France, dans l'ancien statut des personnels d'air France, les hôtesses de l'air doivent cesser leurs fonctions si elles prévoient de se marier³³.

B- Clause de viduité

La nature juridique du mariage fait l'objet d'un grand débat doctrinal, d'autres disent que le mariage est un contrat et d'autres une institution. Cependant la plupart des auteurs ont adopté une conception mixte du mariage, à la fois un contrat et une institution. C'est dans cette optique que Alain SERIAUX affirma que, « *le mariage sera un contrat si on envisage la relation créée entre les époux, et il serait une institution si l'on se penche sur la situation qu'il crée vis-à-vis des tiers et de la société* »³⁴.

Le mariage étant un contrat, les parties peuvent insérer certaines clauses dans leur contrat de mariage pour limiter leur liberté de contracter un autre mariage, d'où la clause de viduité.

La viduité, du latin « *viduitas* », signifie veuf ou veuve³⁵. Après le décès du mari ou après le divorce, la femme doit observer un moment avant de se remarier qu'on appelle délai de viduité. Ce délai est de 130 jours en droit guinéen³⁶. Ce délai permet d'éviter qu'une veuve se remarie étant enceinte de son défunt mari afin d'éviter un problème de présomption de paternité à la naissance de l'enfant. Cela est hors propos.

Dans le cadre de notre étude nous allons mettre l'accent sur la clause de viduité, en tant qu'une clause contractuelle.

En effet, aucune définition légale n'a été consacrée pour la clause de viduité, néanmoins nous allons essayer de proposer une définition à l'image de la clause de célibat. La clause de viduité est une clause insérée dans un acte juridique pour limiter la liberté de se marier d'une personne. Quand on parle de viduité cela nous laisse croire que l'intéressé était déjà marié, donc à sa liberté de remariage. Cette clause est beaucoup plus fréquente en donation entre époux.

En France, l'ancien patron de Volkswagen, Ferdinand PIËCH, avait placé avant sa mort toute sa fortune dans deux fondations autrichiennes, dont les statuts font de sa dernière

³³ Art. 72 du statut du personnel d'air France

³⁴ « la définition civile du mariage », rédigé par Alain SERIAUX, recueil DALLOZ, P, 1966

³⁵ Larousse.fr/dictionnaire

³⁶ Art. 336 du c. civ. g

épouse, Ursula, son héritière, à condition qu'elle ne se remarie pas. Si la dame, âgée de 63 ans, devait à nouveau convoler en justes noces, elle n'aurait plus droit à ce pactole, estimé plus d'un milliard d'euros³⁷.

Dans cette affaire M^e charlotte Butruille-Cardew, avocate associée au sein du cabinet CBBC, spécialiste en droit international de la famille, estime qu'une telle clause de viduité est une violation de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Cet article énonce que « *l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille, selon les lois nationales* ».

La clause de viduité n'est pas interdite : le code civil guinéen n'en fait pas cas. En revanche, la jurisprudence française a précisé le 25 mars 1946, qu'une clause de viduité ne peut être « *réputée non écrite* » que si elle a été « *inspirée par des motifs répréhensibles, dont la preuve incombe à la partie qui en demande l'annulation* »³⁸.

La validité de cette clause est admise a été consacrée par la cour de cassation par un arrêt de sa première chambre civile en date du 13 décembre 2005, affirmant « *qu'aucune disposition légale n'interdit à l'époux qui consent une donation à son conjoint pendant le mariage d'assortir celle-ci d'une condition dont l'inexécution entrainera la révocation . Et la cour a ajouté que la condition de persistance du lien matrimonial n'est pas en soi illicite et est justifiée, sauf intention de nuire, par la nature même de cette libéralité* »³⁹.

Il peut arriver que les parties prévoient aussi des clauses qui vont porter atteinte à leur liberté de choisir leur cocontractant, le contenu et la forme de leur contrat.

³⁷ Rafaële RIVAIS, un testament peut-il imposer le célibat ?, chronique, le 07 septembre 2019.

³⁸ IBIDEM, Rafaële RIVAIS, un testament peut-il imposer le célibat ?, chronique, le 07 septembre 2019.

³⁹ Cass.civ.1, 13 décembre 2005, n°02-14.135

Section 2 : Les clauses limitant la liberté de choisir son cocontractant, le contenu et la forme du contrat

Le contrat permet aux parties de déterminer librement les termes de leur accord. Cette liberté leur permet aussi de limiter leur liberté de choisir le contenu, la forme et leur partenaire contractuel. Aux cours de nos études, nous retrouvons des contrats dans lesquels les parties peuvent limiter leur liberté de choisir leur partenaire contractuel, le contenu et la forme de leur contrat. Parmi lesquels nous avons le pacte de préférence et la promesse unilatérale (paragraphe 1) le contrat d'adhésion et le droit de rémption (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Le pacte de préférence et la promesse unilatérale :

Ce sont deux contrats qui limitent la volonté des parties de choisir leur partenaire contractuel. La différence qui existe entre les deux notions se situe au niveau de la volonté du stipulant. Le débiteur d'un pacte de préférences ne prend pas l'engagement de vendre mais seulement de préférer un cocontractant au cas où il vendrait⁴⁰(1). Contrairement au promettant dans la promesse unilatérale celui-ci s'engage à vendre la chose en question ce qui empêche même la vente c'est le consentement du bénéficiaire(2).

A- Le pacte de préférence

Le pacte de préférence n'a pas été abordé par le législateur guinéen. Nous allons faire appel à son homologue français qui est sa source d'inspiration. En effet selon l'article 1123 al 1^{er} du code civil français : *«le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter»*. Le pacte de préférence est un contrat qui oblige une partie à contracter avec un cocontractant même si elle désire plus faire affaire avec ce dernier car elle limite sa liberté de choisir un partenaire dans le premier contrat qui est le pacte de préférence.

Comme tout autre contrat le pacte de préférence doit respecter certaines conditions pour sa validité(a). Une fois valable le pacte doit être respecté par les parties, le cas contraire il peut y avoir des sanctions (b).

a- Les conditions de validité d'un pacte de préférences

⁴⁰ Dalloz.fr, fiche d'orientation, pacte de préférence-mars 2024

Le pacte de préférence étant un contrat pour sa validité, il doit respecter les conditions de formation des contrats prévues par le code civil⁴¹, le consentement, la capacité, le contenu licite et certain. La prédétermination du prix de vente, la stipulation du délai et le cas échéant la publicité foncière ne sont pas des conditions de validité du pacte de préférence⁴². A part ces conditions du droit commun aucune autre condition spécifique n'est prévue par la loi ni par la jurisprudence. Le cas échéant, pour rendre le pacte opposable aux tiers il est conseillé au rédacteur d'enregistrer le pacte à la conservation foncière⁴³.

b- Les sanctions en cas de violation

En cas de violation du pacte de préférence, la loi et la jurisprudence ont admis trois (3) sanctions :

La première est l'engagement de la responsabilité civile. En effet selon l'article 1123 al 2 du code civil français : « *Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi...* ». Il ressort de cette disposition la possibilité d'engager la responsabilité contractuelle du promettant⁴⁴. Cette réparation peut s'entendre sur le tiers lui-même en engageant sa responsabilité civile délictuelle⁴⁵. Pour éviter que sa responsabilité soit engagée la loi a mis à sa disposition une action interrogatoire, cette action le permet de demander le bénéficiaire de confirmer dans un délai raisonnable l'existence d'un pacte de préférence s'il entend s'en prévaloir⁴⁶.

La deuxième constitue à l'annulation du contrat conclu en violation du pacte de préférence⁴⁷.

⁴¹ Art. 1041 et suivants du c.civ.g.

⁴² Djordje Lazic, avocat, pacte de préférence notion effets, violation et interrogation.

⁴³ Ibidem. Djordje Lazic, avocat, pacte de préférence notion effets, violation et interrogation.

⁴⁴ Cass.civ. 11 juillet 1985, n°84-13 .745.

⁴⁵ Cass.civ.3^e 22 avril 1976, n° 74-15.098 ; cass. Civ.1^{er} 11 juillet 2006, n°03-18 .528

⁴⁶ Art 1123 al 3 et 4 du c.civ.g

⁴⁷ Op.cit. Cass.civ.3^e 22 avril 1976, n° 74-15.098 ; art 1123 al 2 du c. civ.fr

La troisième constitue à la substitution de l'acquéreur au bénéficiaire dans le contrat conclu en violation du pacte⁴⁸.

B- Promesse unilatérale

Selon le code civil guinéen en son article 1078 : « *Celui qui s'engage à conclure un contrat est lié par sa promesse. Le bénéficiaire de la promesse doit lever l'option dans le délai prévu. Le contrat produit à ce moment tous ses effets* ».

Selon l'art 1124 du code civil français : « *la promesse unilatérale est un contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque le consentement du bénéficiaire* ».

Il ressort de ces deux articles que la promesse unilatérale est un contrat dans lequel une personne s'engage à conclure avec une autre pendant un moment donné et pour la formation il suffit que le bénéficiaire accepte.

Toute personne qui s'engage à conclure n'a plus le droit de se rétracter et s'il arrive à le faire cela ne peut empêcher la conclusion du contrat promis⁴⁹. Dans la promesse unilatérale le promettant à l'obligation de conclure même s'il ne le souhaite plus conclure avec le bénéficiaire. En promettant il a perdu sa liberté de choisir son cocontractant⁵⁰.

Tout contrat conclu en violation d'une promesse unilatérale est nul si le tiers n'a pas connaissance de l'existence de cette dernière⁵¹.

La liberté contractuelle peut être limitée dans un contrat d'adhésion et en matière de droit de rémption.

⁴⁸ Cass. Ch. Mixte, 26 mai 2006, n°03-19.376

⁴⁹ Art 1124 al2 du c.civ.fr

⁵⁰ Civ 3^e, 23 juin 2021

⁵¹ Art. 1124 du c.civ.Fr

Paragraphe 2 : Le contrat d'adhésion et le droit de péremption

Le contrat d'adhésion⁽¹⁾ avant de parler du droit de préemption⁽²⁾ sont aussi deux notions qui limitent la liberté contractuelle.

A- Contrat d'adhésion :

Selon l'article 1039 du code civil guinéen, « Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties ». Il ressort de cette disposition que, le contenu du contrat est déterminé par une seule et l'autre ne peut qu'adhérer ou laisser.

C'est un type de contrat standardisé où les termes et conditions sont déterminés par une partie et l'autre partie ne fait qu'accepter les termes déjà fixés limitant ainsi sa liberté de négocier.

Dans ce genre de contrat la partie qui doit adhérer ne peut user que de sa liberté de contracter ou ne pas contracter. Et si elle décide d'adhérer, elle limitera sa liberté de déterminer le contenu et la forme de son contrat.

Ce contrat est une limitation à la liberté contractuelle en ce qu'il empêche la partie adhérente de négocier les termes du contrat. Cependant, le législateur protège cette partie adhérente contre les clauses abusives, assurant un équilibre entre la liberté contractuelle et la protection de la partie la plus fiable.

La partie qui adhère ne peut solliciter la nullité d'un contrat d'adhésion en se fondant sur la liberté contractuelle.

L'intérêt de ce genre de contrat est la rapidité, car la partie qui adhère sera dispenser des pourparlers ou négociations. Cependant, il sera disposé à des risques s'il y trouve des clauses en sa défaveur et à la soumission

B- Le droit de préemption :

Le droit de préemption c'est un droit reconnu à l'Etat ou aux collectivités territoriales d'acquérir en cas d'aliénation, la propriété d'un ou de plusieurs immeubles, ou l'acquisition de droits réels immobiliers, par préférence à tout autre acquéreur⁵². En outre, le droit de préemption est un droit qui permet d'acheter un bien par préférence à toute

⁵² Art 2 de la Loi n° I/2015/ 020/ A.N portant code de la construction et de l'habitation en République de Guinée

autre personne mais seulement si son propriétaire manifeste de façon non équivoque la volonté de le vendre, il peut être d'ordre légal ou par disposition contractuelle.

La liberté contractuelle permet aux parties de négocier et de conclure des contrats. Cependant le droit de préemption introduit une limite à cette liberté puisqu'il impose à un vendeur l'obligation d'offrir le bien en propriété à une personne ou une entité déterminée, dans des conditions.

La droite préemption limite la liberté de choisir son concoctant. C'est une réelle limite à la liberté contractuelle. Par exemple, lorsqu'un bailleur veut céder le logement occupé par un locataire, ce dernier disposer d'un droit de préemption. Dans une société commerciale, les coassociés ont un droit de préemption sur la vente des parts sociales.

Pour empêcher que la partie la plus forte impose sa loi, le législateur a prévu des dispositions d'ordre public pour limiter la liberté contractuelle.

Chapitre II : Les disposition d'ordre public et la liberté contractuelle

Selon l'article 1034 du code civil guinéen, l'ordre public est une limite à la liberté contractuelle (section 1). Le non-respect de ces dispositions d'ordre public entraîne des sanctions (section2).

Section 1 : L'ordre public, une limite à la liberté contractuelle

Il sera nécessaire d'apporter une précision sur la notion d'ordre public (paragraphe 1) avant de parler de son lien avec la liberté contractuelle (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Une précision sémantique de la notion d'ordre public :

L'ordre public est un concept très vaste utilisé dans de nombreux domaines du droit, c'est une notion juridique aux multiples facettes, qui ne revêt pas exactement la même définition selon le contexte et le domaine du droit concerné⁵³. Notamment en droit administratif, l'ordre public désigne la sécurité, la tranquillité, la salubrité. La jurisprudence administrative a ajouté d'autres composantes à savoir, la moralité publique⁵⁴, la dignité humaine⁵⁵. En droit des contrats la notion d'ordre publique est utilisée pour décrire les règles qui ne peuvent être dérogé par des conventions particulières⁵⁶. En général, l'ordre public est défini comme l'ensemble des règles qui touchent à l'organisations de la nation, à l'économie, à la morale, à la santé, à la sécurité, à la paix publique, aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu⁵⁷.

Ces lois peuvent être établies soit pour protéger l'intérêt général, ordre public de direction(A) ; soit pour protéger l'intérêt des particuliers, l'ordre public de protection (B).

A- Ordre publique de direction

L'ordre de direction vise la protection de l'intérêt public en général et tente d'imprégner aux agissements des individus. Il permet donc d'assurer l'implantation d'une politique

⁵³ *Definition-juridique.fr*

⁵⁴ *CE, 18 décembre 1959, société les films lutétia*

⁵⁵ *CE, 27 octobre 1995, commune de morsang-sur-orger.*

⁵⁶ *Art 12 du c.civ.g*

⁵⁷ *Dictionnaire-juridique.com*

d'économie dirigée⁵⁸. Une disposition est d'ordre public de direction lorsque la règle prévue transcende l'intérêt individuel et s'attache davantage à l'intérêt collectif⁵⁹.

L'ordre public de direction concerne la gestion et l'organisation de la société par l'État. Il sert à orienter les politiques publiques, législatives ou réglementaires pour atteindre des objectifs d'intérêt général. Il permet à l'État de fixer des limites à l'autonomie des individus ou des acteurs privés.

Ces dispositions ne peuvent être renoncées par les parties parce que l'intérêt visé par le législateur est celui de la société dans son ensemble. Cet aspect limite la liberté contractuelle des individus, car ils ne peuvent rien prévoir dans leur contrat qui nuira à la société.

C'est pourquoi toute violation de ces dispositions est sanctionnée par la nullité absolue⁶⁰. A titre d'exemple, l'objet d'un contrat doit être licite, on ne peut conclure un contrat de vente portant sur les organes humains en république de Guinée⁶¹.

L'ordre public peut être aussi de protection.

B- L'ordre public de protection

Contrairement à l'ordre public de direction, l'ordre public de protection vise à protéger un intérêt particulier ou privé, généralement celui de la partie la plus démunie dans le rapport de force entre les cocontractants⁶². Par exemple en matière sociale, la loi protège plus l'employé que l'employeur⁶³. L'État intervient également pour protéger les consommateurs face aux entreprises. Il peut ainsi encadrer certaines clauses abusives ou imposer des obligations d'information pour garantir un consentement éclairé. La partie bénéficiant de cette protection peut la renoncer à tout moment. Toutefois, il y a de ces dispositions de protection qui ne peuvent être renoncées par le bénéficiaire, par exemple les conditions de travail prévues par le code du travail.

⁵⁸ Vivent KARIM, « l'ordre public en droit économique : contrats, concurrences, consommation » revue les cahiers de Droit, p.412

⁵⁹ Ibidem, Vivent KARIM, « l'ordre public en droit économique : contrats, concurrences, consommation », revue les cahiers de Droit, P.413

⁶⁰ Art. 1080 du c.civ.gn

⁶¹ Art 1041 du c.civ.gn

⁶² Op. cit, Vivent KARIM, « l'ordre public en droit économique : contrats, concurrences, consommation » revue les cahiers de Droit, p.413

⁶³ Le code du travail en république de Guinée

LES LIMITES A LA LIBERTE CONTRACTUELLE

La violation de ces dispositions est sanctionnée par la nullité relative.

Paragraphe 2 : La liberté contractuelle et l'ordre public, une conciliation légitime :

Selon l'art 1034 du c.civ.gn al in fine « la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public ». Il résulte de cette disposition que, les parties au contrat doivent respecter les dispositions d'ordre public et éviter que l'ordre public soit troublé à cause de leur contrat. Le maintien de l'ordre public étant une nécessité pour l'exercice des libertés, il en découle que dans certaines circonstances les libertés peuvent être limitées pour sauvegarder l'ordre public⁶⁴. Cette limitation est légitime car on ne peut permettre à un individu de nuire à un ensemble.

Comme on l'a souligné ci haut, la violation des dispositions d'ordre public entraîne des sanctions.

⁶⁴ *Conseil constitutionnel.fr*

Section 2 : La sanction découlant de la violation des dispositions d'ordre public

La sanction de la violation des dispositions d'ordre public est la nullité (paragraphe 1). D'autres sanctions se rapprochent de la nullité mais il y a une nuance entre elles (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La nullité

Avant d'aborder le régime juridique de la nullité(B) nous allons une précisons sémantique de la notion de nullité (A).

A- Précision sémantique de la notion de nullité

Le code civil ne fournit pas véritablement de définition de la nullité, néanmoins elle est définie par le lexique des termes juridique de Serge GUIARD et Terry DEBARD comme, une « sanction prononcée par le juge et consistant dans la disparition rétroactive de l'acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation ». La nullité peut être absolue ou relative :

Elle est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général⁶⁵. Elle est relative lorsqu'elle sanctionne une règle dont le seul objet est la sauvegarde d'un intérêt privé⁶⁶.

B- Le régime juridique de la nullité

Nous allons parler du droit d'invoquer la nullité(1) et suivie de son effet(2).

1- Le droit d'invoquer la nullité

Les personnes qui peuvent invoquer la nullité ne sont pas les mêmes selon le type de nullité :

- Le droit d'invoquer la nullité absolue : La nullité absolue peut être invoquée par tout intéresser et en outre par le ministère public ou soulevée d'office par le juge⁶⁷.
- Le droit d'invoquer la nullité relative : elle est invoquée par la personne que la loi protège⁶⁸.

⁶⁵ Art. 1080 du C.civ g

⁶⁶ Art. 1081 du C.civ g

⁶⁷ Al.2 de l'art. 1080 du C.civ g

⁶⁸ Art. 1081 du C.civ g

L'acte qui comporte une cause de nullité peut être validé en raison d'une confirmation ou de l'écoulement du délai de prescription. Le code civil guinéen n'a pas fourni une définition pour la confirmation. En revanche, son homologue français a pris la peine de fournir une définition pour la première fois par le Code civil en son alinéa 1er de l'article 1182 découlant de l'ordonnance du 10 février 2016, comme « l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce ». Cette confirmation n'est pas possible en nullité absolue⁶⁹. Cette interdiction est légitime car une seule personne ne peut renoncer à une chose qui protège tout le monde.

Quant à la prescription, la nullité absolue est soumise à la prescription du droit commun⁷⁰. Et la nullité relative se prescrit conformément à l'article Article 1082 par 2 ans du jour de la formation du contrat. Ce délai court cependant dans les cas d'incapacité ou de violence du jour où elles ont cessé, dans le cas d'erreur ou de dol du jour où le vice a été découvert.

2- Les effets de la nullité

Selon Article 1086 du code civil guinéen : « *Sauf dans le contrat à exécution successive, le contrat nul est réputé n'avoir jamais existé, et les parties doivent restituer ce qu'elles ont reçu* ». Il ressort de cette disposition le caractère rétroactif de la nullité. La nullité du contrat est rétroactive, le contrat disparaît pour l'avenir mais aussi pour le passé, que la nullité soit relative ou absolue. La rétroactivité connaît peu d'exceptions, par exemple: la nullité du contrat de société n'est pas rétroactive⁷¹. Une fois qu'un contrat est nul les parties doivent restituer ce qu'elles ont reçu comme contrepartie. Par exemple un contrat de vente qui porte sur une voiture dont le prix est de 20 000 000 fg est frappé de nullité le vendeur doit restituer le prix qu'il a reçu et l'acheteur doit restituer la voiture à son tour.

L'incapable ne restitue que ce qui reste avec lui le jour de l'annulation⁷². Une personne qui exécute un contrat contraire à l'ordre public ne peut invoquer la nullité, comme on aime le dire souvent que, « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».

⁶⁹ Art. 1080 du C.civ.g

⁷⁰ Art 1270 du c.civ.g : « *Sauf dispositions contraires de la loi, le délai de la prescription de droit commun est de 30 ans* ».

⁷¹ Art. 253 de l'AUSC.GIE

⁷² Art 1087 du c.civ.g

La nullité peut frapper une clause, en principe, la nullité n'affecte que les clauses concernées⁷³. Toutefois, si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles⁷⁴.

Il y a d'autres sanctions qui entraînent l'inefficacité du contrat.

⁷³ Article 1089 du c.civ.g

⁷⁴ Cass. 1re civ. 17 oct. 2007, n° 05-14818

Paragraphe 2 : Les autres sanctions

La nullité doit être distinguée des sanctions voisines, mais différentes, qui entraînent aussi l'inefficacité du contrat, parmi lesquelles la caducité(A) et la résolution (B) qui sont les plus proches de la nullité.

A- La caducité

la caducité n'est pas expressément prévue par le code civil guinéen, cependant son homologue français l'a prévu en ses articles 1186 et 1187 .

Selon l'article 1186 du code civil français, « *un contrat valablement formé devient caduc si l'un des éléments essentiels disparaît* ». Autrement dit, la caducité est la sanction qui frappe le contrat initialement valable mais qui a vu l'un des éléments de validité disparaître au cours de l'exécution.

Que faut-il entendre par « *éléments essentiels* » ? Il est tentant de les ramener aux conditions nécessaires à la validité du contrat⁷⁵, à savoir le consentement, la capacité et le contenu licite et certain. Avant la réforme de 2016, la Cour de cassation ayant déjà admis que la disparition de la « cause » commandait la caducité du contrat⁷⁶. Cependant, la notion d'élément essentiel peut également faire référence à un élément extérieur au contrat qui conditionne sa validité⁷⁷. Il peut agir d'un ensemble contractuel indivisible, où les contrats sont interdépendants, l'anéantissement d'un contrat entraîne la caducité de l'autre⁷⁸. En outre, selon l'article 1186 al.3 « *La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.* » Il ressort de cette disposition qu'en plus le caractère indivisible des contrats il faut que le cocontractant ait connaissance de l'opération de l'ensemble contractuel voire donné son consentement. La caducité met fin au contrat⁷⁹.

⁷⁵ En ce sens : M. Mignot, « *Commentaire article par article de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations* », LPA, 30 mars 2016, p. 7.

⁷⁶ . Civ. 1re, 30 oct. 2008, no 07-17.646

⁷⁷ Fiches-droit .com

⁷⁸ Cass.2 fév.2018 et l'art 1186 al. 2 du c.civ. fr.

⁷⁹ Art. 1187. Ali 1^{er} du code civil français

La caducité peut être rétroactive⁸⁰, ici l'ordonnance se contente d'entériner une solution jurisprudentielle dégagée par un arrêt de la chambre commerciale du 05 juin 2007⁸¹.

La caducité peut frapper certains actes de procédures mais cela est hors propos.

B- La résolution du contrat

Selon l'article 1103 du code civil guinéen, « *La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat* ». Allant de cette disposition nous pouvons en déduire que la résolution est la sanction qui inflige un contrat inexécuté ou mal exécuté. En outre, la résolution est l'annulation des obligations nées d'un contrat synallagmatique à exécution instantanée contrairement à la résiliation qui concerne les contrats à exécution successive.

Il convient de parler à ce niveau des modes de résolution (1) et les effets de la résolution (2)

1- Les modes de résolution du contrat :

Selon l'article 1108 alinéa 1^{er} : « *La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice...* ». Il ressort de cet alinéa trois modes de résolution à savoir : par clause résolutoire (a), par décision unilatérale du créancier(b) ou par décision de justice(c).

a- La résolution du contrat par clause résolutoire

Il est possible de résoudre un contrat par application d'une clause résolution conformément à l'article 1108 susvisé. C'est le cas lorsque le contrat comporte une telle clause, prévoyant par avance les modalités de la sanction applicable en cas d'exécution d'obligation par une des parties.

Selon l'alinéa 2 de l'article 1108 du c.civ.gn : « *La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire* ». Il ressort de cette disposition une

⁸⁰ Art. 1187 al.2 du code civil français

⁸¹ Cass.com. 5 juin 2007

condition qui est une mise en demeure infructueuse préalable si elle est prévue par le contrat.

b- La résolution unilatérale du créancier

Selon l'article 1109 alinéa 1^{er} : « *Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.* ». Selon cet article il est également possible pour un créancier de mettre fin à un contrat unilatéralement. Cette mise en demeure doit mentionner que le créancier pourra résoudre le contrat si le débiteur continue à ne pas exécuter son obligation⁸².

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution⁸³.

c- La résolution judiciaire :

Selon le dernier alinéa de l'article 1109 du c.civ.gn « *La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice* ». Cet alinéa rappelle la possibilité de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat, même si une clause résolutoire a été prévue au contrat, ou même si une procédure de résolution par notification a été engagée.

Selon l'article 1110 al 1^{er} du c.civ.gn « *Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts* ».

Le juge une fois saisi il peut constater la résolution, si celle-ci est intervenue, soit par le jeu d'une clause résolutoire, soit par la résolution unilatérale du créancier. En revanche, le juge peut prononcer la résolution du contrat s'il est saisi d'une action résolutoire. En outre, le juge peut également ordonner l'exécution du contrat ou allouer les dommages et intérêts.

2- Les effets de la résolution

Selon le deuxième alinéa de l'art 1110 du c.civ.gn « *La résolution met fin au contrat* ». La résolution est une cause de rupture du contrat, elle met fin au contrat. La résolution étant rétroactive, les parties sont appelées à la restitution.

⁸² Art.1109 du c.civ .gn

⁸³ Art.1109 du c.civ .gn

Selon l'alinéa 4 de l'article précité « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre ». Cet alinéa montre le caractère rétroactif de la résolution, une fois le contrat est résolu les parties procèdent à la restitution si la prestation échangée trouve son utilité dans l'exécution complète du contrat.

Selon l'alinéa 5 de l'article précité « *Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation* ». Par exemple, un contrat de bail qui a cessé d'être exécuter par le bailleur au bout de trois ans, puis qui a été judiciairement résolu lors de la cinquième année. Les prestations exécutées pendant les trois premières années n'auront pas à être restituées, mais les deux dernières années devront l'être.

Par ailleurs, certaines clauses produisent des effets malgré la résolution du contrat, notamment la clause de non-concurrence, la clause de confidentialité⁸⁴.

Malgré certaines similitudes entre ces sanctions et la nullité il faut retenir qu'il y a une nuance.

La loi est le grand obstacle à la liberté contractuelle, c'est elle qui donne la possibilité aux parties de limiter cette liberté et c'est elle aussi qui donne le pouvoir au juge pour cette même fin qui est d'ailleurs notre deuxième partie.

⁸⁴ Al. In fine. De l'art 1110 du c.civ.gn

**PARTIE 2: L'ENCADREMENT DE LA LIBERTE
CONTRACTUELLE INITIE PAR LE JUGE**

Le contrat s'impose aux parties dès sa conclusion, il s'impose également au juge qui doit l'appliquer tel que les parties l'ont formé. Le juge est soumis à la « loi » des parties qui est le contrat et qui lui sert de base. Cependant, la « loi » des parties est bien souvent une source de litige à laquelle l'intervention judiciaire est nécessaire. Le juge doit alors se prononcer sur le contrat et sur son exécution tout en respectant son contenu. Les parties n'ont pas toujours les connaissances nécessaires pour appréhender la réalité et les engagements qui découlent de certains contrats. Le juge permet alors de rattraper les erreurs et l'éventuel déséquilibre que le contrat contient.

Voilà pourquoi l'analyse détaillée qu'il faut mener à ce propos doit s'articuler autour de l'encadrement pendant la formation du contrat (chapitre I) et celui pendant l'exécution du contrat (chapitre II)

Chapitre I : L'encadrement à la liberté contractuelle initié par le juge lors de la formation du contrat

Pour aménager le contrat le juge passe par son pouvoir interprétatif (section 1) ou celui de la qualification ou la requalification (section 2)

Section 1 : Atteintes à travers le pouvoir interprétatif du juge

L'interprétation, littérairement c'est l'action d'expliquer, de relever la signification d'une chose obscure ; son résultat.⁸⁵ Juridiquement interpréter un contrat consiste à donner une signification claire à la volonté que les parties ont voulu manifester dans le contrat. L'interprétation des contrats relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.⁸⁶

Par ailleurs, Pour interpréter un contrat il y a des méthodes sur lesquelles le juge se focalise (paragraphe 1), après l'interprétation le juge peut mettre à la charge des parties certains devoirs que les parties n'ont pas voulu (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les méthodes interprétatives

Dans l'interprétation du contrat le juge peut utiliser la méthode objective ou subjective (A) et la méthode *in favorem*⁸⁷ (B)

A- La méthode objective ou subjective

La question de la méthode d'interprétation du contrat constitue un point central du rôle du juge dans la formation du lien contractuel. En effet, dès lors que le contrat présente une ambiguïté, une imprécision ou une contradiction apparente, le juge ne peut se contenter d'une lecture mécanique du texte. Il lui revient de déterminer la signification juridique exacte des engagements souscrits par les parties, ce qui implique nécessairement un choix méthodologique⁸⁸.

Traditionnellement, la doctrine distingue deux grandes approches : la méthode subjective et la méthode objective. Ces deux méthodes, loin de s'exclure mutuellement, traduisent

⁸⁵ *dictionnaire.lerobert.com*.

⁸⁶ Jean-Luc Albert et al. sous la direction de Serge Guinchard et Terry Debard, 26^e édition 2018-2019.

⁸⁷ *En faveur d'une partie*

⁸⁸ G. Cornu, *Vocabulaire juridique*, V^o « Interprétation ».

deux conceptions différentes du contrat et, par conséquent, deux manières distinctes d'appréhender la liberté contractuelle.

1. La méthode subjective : la recherche de la volonté réelle des parties

La méthode subjective repose sur l'idée selon laquelle le contrat est avant tout l'expression d'une volonté commune. Dans cette perspective, les stipulations écrites ne constituent qu'un moyen, parfois imparfait, de traduire l'intention véritable des cocontractants. Le rôle du juge consiste alors à rechercher ce que les parties ont réellement voulu au moment de la conclusion du contrat, même si cette volonté n'a pas été exprimée avec une précision suffisante⁸⁹.

Cette approche trouve son fondement dans la théorie classique de l'autonomie de la volonté, selon laquelle la force obligatoire du contrat découle exclusivement de l'accord des volontés. Dès lors, il serait artificiel de s'arrêter à la seule lettre du contrat lorsque celle-ci ne reflète pas fidèlement l'intention commune⁹⁰.

Dans l'exercice de cette méthode, le juge prend en considération divers éléments extrinsèques au contrat. Il peut notamment s'appuyer sur :

- les circonstances entourant la conclusion de l'acte,
- le comportement antérieur ou postérieur des parties,
- les usages professionnels applicables,
- les échanges précontractuels lorsque ceux-ci permettent d'éclairer la commune intention⁹¹.

La jurisprudence admet de longue date cette démarche. Il a ainsi été jugé que, lorsque les termes du contrat sont ambigus, le juge doit rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des mots employés⁹². Cette solution confère au juge un pouvoir appréciable, car elle l'autorise à dépasser le texte contractuel pour reconstruire la volonté réelle des cocontractants.

⁸⁹ F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, *Droit civil – Les obligations*, Dalloz.

⁹⁰ J. Carbonnier, *Droit civil – Les obligations*, PUF.

⁹¹ Ph. Malaurie, L. Aynès, *Les obligations*, LGDJ.

⁹² Cass. civ. 1re, *principe de recherche de la commune intention des parties*.

Toutefois, cette méthode n'est pas sans limites. En privilégiant l'intention réelle sur l'expression écrite, le juge s'expose au risque de substituer sa propre appréciation à celle des parties. La liberté contractuelle s'en trouve alors indirectement affectée, dans la mesure où le contenu du contrat peut être déterminé a posteriori par une interprétation judiciaire fondée sur des éléments parfois subjectifs.

2. La méthode objective : la primauté du sens littéral et raisonnable

À l'opposé, la méthode objective repose sur une conception plus formaliste du contrat. Selon cette approche, le juge doit s'en tenir au sens clair et précis des stipulations contractuelles, telles qu'elles peuvent être comprises par une personne raisonnable placée dans la même situation⁹³.

Cette méthode trouve sa justification principale dans la recherche de la sécurité juridique. En effet, si les parties ne pouvaient se fier au contenu écrit de leur contrat, la prévisibilité des relations contractuelles serait gravement compromise. La méthode objective permet ainsi de garantir la stabilité des engagements et d'éviter les remises en cause opportunistes fondées sur des intentions supposées⁹⁴.

La jurisprudence consacre cette approche en affirmant de manière constante que les clauses claires et précises ne doivent pas être interprétées, mais appliquées telles quelles⁹⁵. Dans ce cas, le juge n'a pas à rechercher une intention cachée ou implicite ; il lui suffit de donner effet à la lettre du contrat.

Cette conception limite, en apparence, l'intervention judiciaire et semble davantage respectueuse de la liberté contractuelle. Les parties restent maîtresses du contenu de leur accord, dès lors qu'elles ont exprimé leur volonté de manière claire et non équivoque.

Cependant, cette objectivation de l'interprétation n'est pas absolue. Elle suppose que le contrat soit rédigé avec une précision suffisante, ce qui est loin d'être toujours le cas en pratique, notamment dans les contrats complexes ou techniques.

3. La combinaison des deux méthodes : une liberté contractuelle encadrée

⁹³ F. Terré, *Introduction générale au droit*, Dalloz.

⁹⁴ J.-L. Aubert, *Droit des obligations*, Sirey.

⁹⁵ Cass. civ. I, *re, clauses claires et précises, refus d'interprétation*.

En pratique, la jurisprudence ne retient ni une approche exclusivement subjective ni une approche strictement objective. Les juges combinent ces deux méthodes en fonction des circonstances propres à chaque affaire⁹⁶.

Lorsque les stipulations contractuelles sont claires, la méthode objective prévaut et le juge s'interdit toute interprétation créatrice. En revanche, dès lors qu'une ambiguïté apparaît, le juge retrouve la faculté de rechercher la volonté réelle des parties. Cette alternance confère au juge une marge d'appréciation importante, qui constitue une limite structurelle à la liberté contractuelle.

En effet, même lorsque les parties ont librement négocié et rédigé leur contrat, le sens définitif de leurs engagements peut être fixé par le juge en cas de litige. Le contrat cesse alors d'être exclusivement l'œuvre des parties pour devenir un objet d'interprétation judiciaire. Cette réalité illustre le passage progressif d'un modèle purement volontariste à un modèle plus encadré, dans lequel la liberté contractuelle demeure reconnue, mais étroitement surveillée.

B- La méthode *in favorem*

La méthode *in favorem* constitue une technique d'interprétation particulière par laquelle le juge tranche les ambiguïtés contractuelles en faveur de la partie considérée comme la plus faible ou, inversement, contre celle qui a rédigé le contrat. Elle repose sur l'idée selon laquelle l'incertitude née d'une clause obscure ne doit pas profiter à celui qui était en mesure d'en maîtriser la rédaction⁹⁷.

Cette méthode trouve une consécration explicite en droit positif, notamment à travers les dispositions relatives aux contrats d'adhésion. En effet, lorsque les conditions générales sont déterminées unilatéralement par une partie et soustraites à toute négociation réelle, l'autre partie se trouve placée dans une situation de vulnérabilité juridique structurelle⁹⁸. Dans un tel contexte, l'interprétation *in favorem* apparaît comme un correctif nécessaire à l'inégalité contractuelle.

1. Fondements juridiques et doctrinaux de la méthode *in favorem*

⁹⁶ *Jurisprudence constante relative au pouvoir souverain d'interprétation des juges du fond.*

⁹⁷ G. Cornu, *Vocabulaire juridique*, V° « Interprétation ».

⁹⁸ Art. 1039, *Code civil guinéen*.

La méthode *in favorem* s'inscrit dans une évolution plus large du droit des contrats, marquée par le recul progressif du volontarisme absolu et par la montée en puissance des considérations de protection. Traditionnellement, l'interprétation du contrat visait exclusivement la recherche de la volonté commune. Toutefois, cette approche s'est révélée insuffisante dans les hypothèses où la volonté de l'une des parties domine largement celle de l'autre⁹⁹.

La doctrine souligne que, dans les contrats d'adhésion, la notion même de volonté commune est parfois fictive. L'adhérent n'exprime pas une volonté librement négociée, mais se borne à accepter un ensemble de clauses préétablies¹⁰⁰. Dès lors, rechercher une commune intention dans de telles situations reviendrait à ignorer la réalité du rapport de forces contractuel.

C'est précisément pour pallier cette difficulté que la méthode *in favorem* a été consacrée. Elle permet au juge de ne pas s'enfermer dans une analyse purement volontariste et d'introduire une dimension protectrice dans l'interprétation du contrat.

2. Application privilégiée dans les contrats d'adhésion

La méthode *in favorem* trouve son terrain d'élection dans les contrats d'adhésion, définis comme ceux dont les conditions générales sont fixées à l'avance par une partie et ne sont pas susceptibles de négociation¹⁰¹. Dans ces contrats, l'adhérent n'a, en pratique, d'autre choix que d'accepter ou de refuser le contrat dans son ensemble.

Lorsque de telles conventions comportent des clauses ambiguës, la jurisprudence considère que cette ambiguïté doit être interprétée contre le stipulant, c'est-à-dire contre la partie qui a rédigé le contrat¹⁰². Ce principe repose sur une logique simple : celui qui rédige une clause obscure doit en supporter les conséquences.

Cette solution permet de responsabiliser le rédacteur du contrat et de l'inciter à formuler des stipulations claires et intelligibles. Elle participe ainsi à une amélioration globale de

⁹⁹ J. Carbonnier, *Droit civil – Les obligations*, PUF.

¹⁰⁰ F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, *Droit civil – Les obligations*, Dalloz.

¹⁰¹ Ph. Malaurie, L. Aynès, *Les obligations*, LGDJ.

¹⁰² Cass. civ. 1re, *interprétation des clauses obscures contre le stipulant*.

la qualité rédactionnelle des contrats, tout en assurant une meilleure protection de la partie adhérente.

3. Une interprétation orientée vers la protection de la partie faible

Au-delà des contrats d'adhésion, la méthode *in favorem* peut également être mobilisée chaque fois qu'un déséquilibre manifeste existe entre les cocontractants. Le juge apprécie alors concrètement la situation des parties, leur degré d'information, leur expérience ainsi que leur pouvoir de négociation¹⁰³.

Dans cette perspective, l'interprétation cesse d'être un simple exercice intellectuel de clarification. Elle devient un instrument de régulation contractuelle. Le juge ne cherche plus uniquement à comprendre ce que les parties ont voulu, mais à éviter que l'ambiguïté contractuelle ne serve de vecteur d'abus.

Cette orientation protectrice marque une évolution significative du rôle du juge. Celui-ci n'est plus seulement l'arbitre neutre de la volonté contractuelle, mais un acteur chargé de rétablir un certain équilibre dans les relations contractuelles.

4. Une atteinte assumée à la liberté contractuelle

Il convient de souligner que la méthode *in favorem* constitue, par nature, une atteinte à la liberté contractuelle du rédacteur du contrat. En effet, ce dernier voit sa liberté d'organisation contractuelle limitée par une interprétation judiciaire défavorable en cas d'ambiguïté.

Toutefois, cette atteinte apparaît largement justifiée au regard des objectifs poursuivis. La liberté contractuelle ne saurait servir de fondement à des pratiques abusives ou à l'exploitation d'une position dominante. En ce sens, la méthode *in favorem* participe d'une conception moderne du contrat, dans laquelle la liberté des parties est conciliée avec des exigences de justice et d'équité¹⁰⁴.

Ainsi, par le biais de cette méthode, le juge assume pleinement un rôle correcteur. Il dépasse la simple recherche de la volonté commune pour introduire une logique de

¹⁰³ Doctrine relative à la protection de la partie faible dans le contrat.

¹⁰⁴ Art. 1190, Code civil français.

LES LIMITES A LA LIBERTE CONTRACTUELLE

protection, contribuant ainsi à encadrer la liberté contractuelle dans les situations où celle-ci risque de produire des effets manifestement déséquilibrés.

Paragraphe 2 : La naissance des nouveaux devoirs découlant de l'interprétation

Le juge peut aussi aménager le contrat par son pouvoir de qualification et requalification

Section 2 : Atteintes à travers le pouvoir de qualification et requalification par le juge

La qualification est la transposition de la règle de droit aux faits auxquels elle doit s'appliquer. C'est un mécanisme à caractère juridique qui par essence relève de la compétence du juge.

A ce niveau nous allons parler des types de qualification ou de requalification (paragraphe 1) avant d'aborder le sort du contrat qualifié ou requalifié (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Les types de qualification et requalification

Le juge peut requalifier un contrat en augmentant les obligations des parties(A) ou en diminuant la valeur de l'acte(B)

A- La requalification par majoration

La requalification par majoration constitue l'une des manifestations les plus significatives de l'intervention du juge dans la formation du contrat. Elle intervient lorsque le juge estime que la qualification retenue par les parties ne correspond pas à la réalité juridique de l'opération conclue. Dans ce cas, il substitue à la qualification apparente celle qu'il juge conforme à la nature réelle des faits, entraînant l'application d'un régime juridique plus contraignant¹⁰⁵.

Ce mécanisme repose sur un principe fondamental : la qualification juridique d'un acte ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties, mais de la réalité objective de la situation contractuelle. Les parties peuvent qualifier leur contrat comme elles l'entendent, cette qualification ne lie pas le juge¹⁰⁶. Celui-ci dispose d'un pouvoir souverain pour restituer aux faits leur véritable qualification juridique.

1. La requalification comme instrument de révélation de la réalité contractuelle

La requalification par majoration trouve une illustration classique dans le contentieux de la requalification des contrats de prestation de services en contrats de travail. En présence d'un contrat présenté comme civil ou commercial, le juge peut constater que les

¹⁰⁵ XXG. Cornu, *Introduction au droit*, Montchrestien.

¹⁰⁶ F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, *Droit civil – Les obligations*, Dalloz.

conditions d'exécution révèlent en réalité l'existence d'un lien de subordination juridique permanent, caractéristique du contrat de travail¹⁰⁷.

Selon une jurisprudence constante, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné¹⁰⁸. Lorsque ces éléments sont réunis, la qualification retenue par les parties est écartée au profit de celle de contrat de travail, indépendamment de leur volonté initiale.

Cette requalification entraîne l'application immédiate de l'ensemble du droit du travail, avec toutes les obligations qui en découlent pour l'employeur : paiement des cotisations sociales, respect des règles relatives à la durée du travail, au licenciement, à la protection sociale, entre autres¹⁰⁹. Le contrat se voit ainsi « majoré » sur le plan juridique, tant par l'intensité des obligations imposées que par le caractère impératif des règles applicables.

2. Une atteinte directe à la liberté contractuelle des parties

La requalification par majoration constitue une atteinte manifeste à la liberté contractuelle. Les parties avaient librement choisi la qualification de leur contrat, ainsi que le régime juridique qu'elles estimaient le plus adapté à leurs intérêts. L'intervention du juge remet en cause ce choix en leur imposant un cadre normatif qu'elles n'avaient pas expressément accepté.

Toutefois, cette atteinte est justifiée par la nécessité de protéger l'ordre public, notamment l'ordre public social. Le droit du travail, comme d'autres branches protectrices, repose sur des règles impératives auxquelles il ne peut être dérogé par la volonté individuelle¹¹⁰. La liberté contractuelle trouve ici une limite structurelle : elle ne saurait permettre de contourner des règles destinées à protéger la partie économiquement ou juridiquement la plus faible.

¹⁰⁷ Cass. soc., principe de requalification des contrats de prestation en contrat de travail.

¹⁰⁸ Cass. soc., définition du lien de subordination juridique.

¹⁰⁹ J. Pélessier, A. Supiot, A. Jeammaud, *Droit du travail*, Dalloz.

¹¹⁰ Art. 1034, *Code civil guinéen (limites liées à l'ordre public)*.

La doctrine souligne à cet égard que la requalification judiciaire constitue moins une sanction qu'un mécanisme de correction. Elle vise à empêcher que des montages contractuels artificiels ne servent à éluder l'application de règles impératives¹¹¹.

3. L'extension de la requalification par majoration à d'autres domaines contractuels

Si le droit du travail constitue le terrain privilégié de la requalification par majoration, ce mécanisme n'y est pas limité. Le juge peut également y recourir dans d'autres domaines, notamment en matière de baux, de contrats de distribution ou encore de contrats de crédit.

Ainsi, un contrat qualifié de prêt peut être requalifié en opération de crédit réglementée lorsque les conditions d'octroi et de remboursement révèlent une activité relevant du monopole bancaire¹¹². De même, un contrat de location peut être requalifié en bail commercial lorsque les conditions d'exploitation du fonds répondent aux critères légaux, entraînant l'application d'un statut plus protecteur pour le preneur.

Dans toutes ces hypothèses, la requalification par majoration a pour effet d'introduire des obligations supplémentaires à la charge de l'une des parties, obligations issues de règles d'ordre public auxquelles il n'est pas possible de se soustraire.

4. Le juge, garant de l'ordre public et de l'équilibre contractuel

À travers la requalification par majoration, le juge assume pleinement son rôle de garant de l'ordre public. Il veille à ce que la liberté contractuelle ne soit pas utilisée comme un instrument de contournement des règles impératives. Cette fonction correctrice traduit une conception moderne du contrat, dans laquelle la volonté des parties n'est plus souveraine, mais intégrée dans un cadre normatif plus large.

La liberté contractuelle demeure un principe fondamental, mais elle se trouve encadrée par l'intervention judiciaire chaque fois que la qualification choisie par les parties apparaît incompatible avec la réalité juridique de l'opération. La requalification par majoration

¹¹¹ J. Carbonnier, *Droit civil – Les obligations*, PUF.

¹¹² Doctrine et jurisprudence relatives au monopole bancaire et à la requalification des opérations de crédit.

illustre ainsi l'équilibre recherché entre autonomie de la volonté et protection des intérêts jugés essentiels par le législateur¹¹³.

B- La requalification par réduction

À l'inverse de la requalification par majoration, la requalification par réduction consiste, pour le juge, à atténuer les effets juridiques d'un acte lorsque ceux-ci apparaissent excessifs, déséquilibrés ou manifestement injustifiés au regard de l'économie générale du contrat. Il ne s'agit pas ici de soumettre l'acte à un régime plus contraignant, mais de restreindre sa portée afin de préserver un certain équilibre contractuel¹¹⁴.

Cette technique s'inscrit dans une logique correctrice. Le juge ne remet pas nécessairement en cause l'existence même du contrat, mais intervient pour neutraliser, moduler ou réduire certains effets jugés excessifs. Par cette démarche, il limite l'efficacité de la volonté contractuelle lorsque celle-ci conduit à des situations contraires à l'équité ou aux exigences de justice contractuelle.

1. La neutralisation des clauses excessives ou abusives

La requalification par réduction trouve une application privilégiée dans le contrôle des clauses contractuelles excessives. Il peut s'agir, par exemple, de clauses pénales manifestement disproportionnées, de clauses limitatives de responsabilité trop restrictives ou encore d'engagements dont la charge apparaît manifestement excessive pour l'une des parties¹¹⁵.

La jurisprudence admet de longue date que le juge puisse intervenir pour réduire le montant d'une clause pénale lorsqu'elle est manifestement excessive. Ce pouvoir de modération permet d'éviter que la sanction contractuelle ne se transforme en instrument de pression ou d'enrichissement injustifié¹¹⁶. Dans ce cas, le juge ne supprime pas la clause, mais en réduit les effets afin de les rendre proportionnés à l'inexécution constatée.

¹¹³ Ph. Malaurie, L. Aynès, *Les obligations*, LGDJ.

¹¹⁴ G. Cornu, *Introduction au droit*, Montchrestien. G. Cornu, *Introduction au droit*, Montchrestien.

¹¹⁵ Ph. Malaurie, L. Aynès, *Les obligations*, LGDJ.

¹¹⁶ Cass. civ., *pouvoir de modération de la clause pénale par le juge*.

Cette intervention traduit une volonté de préserver le contrat tout en en corrigeant les excès. Elle constitue ainsi une alternative à l'annulation pure et simple, jugée parfois trop radicale au regard des intérêts en présence.

2. La réduction comme outil de préservation de l'équilibre contractuel

Au-delà des clauses pénales, la requalification par réduction peut concerner des engagements contractuels dont l'étendue apparaît disproportionnée. Le juge peut alors limiter la portée d'un engagement, notamment lorsqu'il constate un déséquilibre significatif entre les prestations respectives des parties¹¹⁷.

Cette démarche s'inscrit dans une conception renouvelée du contrat, dans laquelle l'équilibre des prestations devient un critère d'appréciation de la validité et de l'efficacité des stipulations contractuelles. La liberté contractuelle demeure, mais elle se trouve encadrée par une exigence de proportionnalité.

Dans cette perspective, la réduction judiciaire des effets du contrat permet d'éviter que la partie la plus forte n'impose des conditions excessivement contraignantes à son cocontractant. Le juge agit alors comme un régulateur, chargé de corriger les déséquilibres les plus manifestes sans remettre en cause l'économie générale du contrat.

3. Une intervention mesurée du juge sur la volonté contractuelle

Contrairement à la requalification par majoration, la requalification par réduction se caractérise par son caractère mesuré. Le juge n'impose pas un nouveau régime juridique global, mais procède à des ajustements ciblés. Cette intervention limitée vise à concilier le respect de la volonté contractuelle avec la nécessité de prévenir des effets excessifs ou injustes¹¹⁸.

Il convient de souligner que le juge n'intervient pas de manière systématique. La réduction des effets du contrat suppose la constatation d'un caractère manifestement excessif ou disproportionné. Cette exigence permet de préserver une marge de liberté aux parties tout en évitant les dérives les plus flagrantes.

¹¹⁷ *Doctrine relative au déséquilibre significatif dans les relations contractuelles.*

¹¹⁸ F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, *Droit civil – Les obligations*, Dalloz.

La doctrine observe à cet égard que la requalification par réduction participe d'un mouvement de « civilisation » du contrat, dans lequel la liberté contractuelle est maintenue, mais encadrée par des mécanismes correcteurs destinés à en limiter les abus¹¹⁹.

4. Une atteinte relative mais réelle à la liberté contractuelle

La requalification par réduction constitue indéniablement une atteinte à la liberté contractuelle, en ce qu'elle limite l'efficacité de certaines stipulations librement consenties. Toutefois, cette atteinte demeure relative. Le juge n'efface pas la volonté des parties, mais en tempère les effets lorsque ceux-ci excèdent ce qui peut être raisonnablement admis.

Cette technique illustre l'équilibre recherché entre autonomie de la volonté et justice contractuelle. Elle témoigne d'une évolution du droit des contrats vers une approche plus pragmatique, dans laquelle la liberté contractuelle n'est plus conçue comme un absolu, mais comme un principe devant être concilié avec des exigences supérieures d'équité et de protection des parties vulnérables¹²⁰.

¹¹⁹ J. Carbonnier, *Droit civil – Les obligations*, PUF.

¹²⁰ Art. 1034, *Code civil guinéen (liberté contractuelle et limites)*.

Paragraphe 2 : Le sort du contrat découlant de la qualification ou requalification

Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire le juge peut maintenir un contrat contre la volonté des parties.

Une fois le contrat qualifié ou requalifié par le juge, les effets juridiques qui en découlent s'imposent aux parties, indépendamment de la volonté qu'elles avaient initialement exprimée. La qualification judiciaire produit ainsi des conséquences directes et immédiates sur le régime applicable à l'acte, sur les droits et obligations des cocontractants, ainsi que sur la pérennité du lien contractuel lui-même.

Cette situation révèle une réalité fondamentale du droit des contrats contemporain : la qualification juridique ne constitue pas une simple opération technique, mais un acte normatif à part entière, susceptible de transformer profondément l'économie du contrat¹²¹.

1. L'autorité de la qualification judiciaire sur les parties

La qualification ou la requalification opérée par le juge s'impose aux parties avec autorité. Une fois que le juge a retenu la qualification qu'il estime conforme à la réalité juridique des faits, les cocontractants ne peuvent s'y soustraire en invoquant leur volonté initiale ou les stipulations contractuelles qu'ils avaient librement convenues¹²².

Ce principe découle du caractère impératif de certaines règles juridiques applicables au contrat. Lorsque la qualification retenue par le juge conduit à l'application de normes d'ordre public, celles-ci s'imposent aux parties de plein droit. La volonté contractuelle se trouve alors reléguée au second plan, au profit d'un cadre normatif supérieur destiné à protéger des intérêts jugés essentiels par le législateur¹²³.

Il en résulte que le contrat, tel qu'il avait été initialement conçu, peut voir son régime juridique profondément modifié sans que les parties aient la faculté de s'y opposer. Cette autorité de la qualification judiciaire constitue une limite structurelle à la liberté contractuelle.

¹²¹ G. Cornu, *Introduction au droit*, Montchrestien.

¹²² F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, *Droit civil – Les obligations*, Dalloz.

¹²³ Art. 1034, *Code civil guinéen (limites de la liberté contractuelle liées à l'ordre public)*.

2. Le maintien du contrat malgré la volonté contraire des parties

Dans certains cas, la qualification ou la requalification du contrat conduit le juge à maintenir le lien contractuel, y compris lorsque les parties expriment le souhait d'y mettre fin. Cette situation peut paraître paradoxale au regard du principe de l'autonomie de la volonté. Toutefois, elle se justifie par la nature des intérêts protégés.

Le juge peut ainsi considérer que la disparition du contrat serait contraire à l'ordre public ou préjudiciable à la partie faible. Dans ce cas, le maintien du contrat apparaît comme un moyen de garantir l'effectivité des règles protectrices applicables à la relation juridique concernée¹²⁴.

Cette faculté est particulièrement manifeste dans les hypothèses où la requalification entraîne l'application d'un statut légal impératif, comme en matière de contrat de travail ou de baux protégés. Le juge peut alors refuser de donner effet à la volonté des parties de rompre le contrat afin de préserver les droits attachés à la qualification retenue¹²⁵.

Par cette intervention, le juge ne se substitue pas entièrement aux parties, mais il encadre leur liberté en fonction des exigences de protection et de stabilité des relations contractuelles.

3. Les effets juridiques du contrat qualifié ou requalifié

La qualification judiciaire produit des effets juridiques étendus. Elle détermine non seulement le régime applicable pour l'avenir, mais peut également produire des effets rétroactifs. Ainsi, une requalification peut conduire à l'application rétroactive de règles protectrices à des situations antérieures, notamment en matière sociale ou fiscale¹²⁶.

Cette rétroactivité renforce l'impact de la qualification judiciaire sur la liberté contractuelle. Les parties se trouvent soumises à des obligations qu'elles n'avaient pas anticipées au moment de la conclusion du contrat. Toutefois, cette conséquence est admise dès lors qu'elle vise à rétablir la conformité du contrat avec les exigences légales.

¹²⁴ *Doctrine relative au maintien judiciaire du contrat en présence d'intérêts protégés.*

¹²⁵ *Cass. soc., jurisprudence relative au maintien du contrat de travail après requalification.*

¹²⁶ *Cass. soc., effets rétroactifs de la requalification.*

En outre, la qualification judiciaire peut entraîner la neutralisation ou l'inopposabilité de certaines clauses contractuelles incompatibles avec le régime applicable. Le contrat est alors maintenu, mais épuré de ses stipulations contraires à l'ordre public ou à la protection légale accordée à l'une des parties¹²⁷.

4. Le juge comme régulateur des relations contractuelles

Le sort du contrat découlant de la qualification ou de la requalification met en évidence le rôle central du juge dans la régulation des relations contractuelles. Loin de se limiter à un contrôle formel, le juge participe activement à la structuration du lien contractuel, en veillant à sa conformité aux normes impératives et aux exigences d'équité.

Cette évolution traduit un déplacement progressif du centre de gravité du contrat. Celui-ci n'est plus exclusivement régi par la volonté des parties, mais s'inscrit dans un cadre normatif plus large, au sein duquel le juge exerce une fonction de garantie et de correction¹²⁸.

Ainsi, le maintien du contrat contre la volonté des parties, lorsqu'il est justifié par l'intérêt protégé, apparaît comme l'expression la plus aboutie de l'encadrement judiciaire de la liberté contractuelle. Il consacre une conception moderne du contrat, dans laquelle l'autonomie de la volonté demeure un principe fondamental, mais nécessairement limité par des considérations supérieures d'ordre public et de justice contractuelle.

¹²⁷ Ph. Malaurie, L. Aynès, *Les obligations*, LGDJ.

¹²⁸ J. Carbonnier, *Droit civil – Les obligations*, PUF.

Chapitre II : Les atteintes à la liberté contractuelle liées au maintien du contrat par le juge

Dans l'exécution du contrat, les parties peuvent rencontrer des difficultés, pour remédier à cela le juge peut intervenir soit pour aménager le contrat (chapitre I) soit pour maintenir le contrat si la cause pouvait mettre fin au contrat (chapitre II).

Le juge peut maintenir un contrat annulable ou résolutoire dont l'annulation ou la résolution est voulu par les parties (section 1), le juge peut aussi maintenir un contrat en procédant à la révision du contrat en cas d'imprévision (section 2)

Section 1 : Le maintien d'un contrat susceptible d'être anéanti

Les parties peuvent vouloir l'annulation d'un contrat (paragraphe 1) ou la résolution d'un contrat et le juge passe outre et que le juge le maintienne quand même (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le maintien d'un contrat annulable par le juge

Le contrat annulable est celui qui, bien que valablement formé en apparence, est entaché d'un vice affectant l'une des conditions de sa formation. Il s'agit notamment des vices du consentement, de l'incapacité ou encore de certaines irrégularités tenant au contenu de l'acte. En principe, un tel contrat est exposé à l'annulation à la demande de la partie que la loi entend protéger¹²⁹.

Toutefois, l'annulabilité du contrat ne signifie pas nécessairement son anéantissement automatique. Le droit positif reconnaît au juge la faculté de maintenir le contrat, même en présence d'une cause de nullité relative, lorsque les circonstances le justifient et que l'intérêt protégé ne commande pas une disparition pure et simple du lien contractuel¹³⁰. Cette intervention judiciaire constitue une atteinte directe à la liberté contractuelle, dans la mesure où elle limite la faculté des parties de mettre fin à un contrat qu'elles ne souhaitent plus maintenir.

1. Le principe de l'annulation relative et la marge d'appréciation du juge

La nullité relative a pour finalité essentielle la protection d'un intérêt privé. Elle peut être invoquée uniquement par la partie que la loi entend protéger, et celle-ci dispose en

¹²⁹ G. Cornu, *Vocabulaire juridique*, V° « Nullité ».

¹³⁰ F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, *Droit civil – Les obligations*, Dalloz.

principe de la liberté de demander ou non l'annulation du contrat¹³¹. Cette faculté s'inscrit dans la logique de l'autonomie de la volonté, en ce qu'elle permet à la partie lésée de choisir entre la disparition du contrat et son maintien.

Cependant, cette liberté n'est pas absolue. Le juge conserve un pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de prononcer l'annulation. Il peut ainsi refuser de faire droit à une demande d'annulation lorsque celle-ci apparaît abusive, tardive ou contraire à l'économie générale du contrat¹³². Dans une telle hypothèse, le maintien du contrat s'impose aux parties, même si l'une d'elles sollicitait expressément son anéantissement.

Ce pouvoir s'explique par la volonté de prévenir les comportements opportunistes. Il ne serait pas conforme à l'équité de permettre à une partie de se prévaloir d'un vice mineur ou ancien pour se dégager d'un engagement devenu économiquement défavorable.

2. La confirmation du contrat comme fondement du maintien judiciaire

Le maintien du contrat annulable peut également résulter de la confirmation de l'acte par la partie protégée. La confirmation est définie comme l'acte par lequel une personne renonce à se prévaloir de la nullité relative dont le contrat est entaché¹³³. Elle peut être expresse ou tacite, notamment lorsque la partie exécute volontairement le contrat en connaissance du vice.

Lorsque le juge constate l'existence d'une confirmation valable, il ne peut prononcer l'annulation du contrat. Celui-ci est alors définitivement consolidé et produit l'ensemble de ses effets juridiques. Dans ce cas, le maintien du contrat ne résulte pas d'une décision discrétionnaire du juge, mais de la renonciation volontaire de la partie protégée à son droit d'agir en nullité¹³⁴.

Toutefois, le juge joue un rôle déterminant dans l'appréciation des conditions de la confirmation. Il lui appartient de vérifier que la renonciation est libre, éclairée et postérieure à la disparition du vice. À défaut, la confirmation est inopérante et le contrat demeure annulable.

¹³¹ Art. 1082, Code civil guinéen (nullité relative).

¹³² Jurisprudence relative au contrôle judiciaire de la demande en nullité.

¹³³ Art. 1182, Code civil français (définition de la confirmation).

¹³⁴ Ph. Malaurie, L. Aynès, *Les obligations*, LGDJ.

3. Le maintien du contrat au nom de la stabilité des relations contractuelles

Au-delà de la confirmation, le juge peut maintenir un contrat annulable en se fondant sur des considérations tenant à la stabilité des relations contractuelles. La doctrine souligne que l'annulation rétroactive du contrat peut parfois entraîner des conséquences excessives, tant pour les parties que pour les tiers¹³⁵.

Dans cette perspective, le juge peut estimer que l'anéantissement du contrat n'est ni nécessaire ni proportionné au regard de la gravité du vice constaté. Il privilégie alors la conservation du contrat, notamment lorsque celui-ci a déjà reçu un commencement d'exécution important ou lorsqu'il s'inscrit dans une relation contractuelle durable.

Ce choix traduit une évolution du droit des contrats vers une logique de conservation plutôt que de destruction du lien contractuel. Le contrat n'est plus systématiquement frappé de nullité dès lors qu'un vice est établi ; il peut être maintenu lorsque l'intérêt protégé peut être sauvegardé par d'autres moyens.

4. Une atteinte assumée à la liberté contractuelle

Le maintien judiciaire d'un contrat annulable constitue une atteinte manifeste à la liberté contractuelle. La partie protégée se voit privée de la faculté de mettre fin au contrat, tandis que l'autre partie est contrainte de poursuivre une relation contractuelle qu'elle n'avait pas nécessairement anticipée dans ces conditions.

Toutefois, cette atteinte apparaît justifiée par la finalité même de la nullité relative. Celle-ci n'a pas vocation à sanctionner l'acte, mais à protéger un intérêt particulier. Dès lors que cet intérêt est préservé, le maintien du contrat peut être admis sans remettre en cause l'équilibre général du système contractuel¹³⁶.

Ainsi, à travers le maintien du contrat annulable, le juge affirme son rôle de régulateur des relations contractuelles. Il ne se contente plus d'appliquer mécaniquement les sanctions prévues par la loi, mais apprécie leur opportunité au regard des circonstances de l'espèce. Cette approche consacre une conception moderne de la liberté contractuelle,

¹³⁵ J. Carbonnier, *Droit civil – Les obligations*, PUF.

¹³⁶ Doctrine relative à la fonction protectrice de la nullité relative.

LES LIMITES A LA LIBERTE CONTRACTUELLE

conçue non comme un absolu, mais comme un principe devant être concilié avec des exigences supérieures de stabilité et d'équité.

Paragraphe 2 : le refus de la résolution par le juge

En cas d'imprévision, le juge peut réviser un contrat à défaut d'accord entre les parties avec les conditions qu'il fixe¹³⁷.

La résolution constitue, en principe, la sanction normale de l'inexécution d'un contrat synallagmatique. Elle permet à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, de mettre fin au contrat et d'obtenir, le cas échéant, réparation du préjudice subi¹³⁸. Cette faculté participe directement de la liberté contractuelle, en ce qu'elle offre aux parties la possibilité de se délier d'un engagement devenu insatisfaisant.

Toutefois, le droit positif reconnaît au juge la possibilité de refuser la résolution du contrat, même lorsque les conditions légales de l'inexécution sont réunies. Ce pouvoir marque une atteinte directe à la liberté contractuelle, dans la mesure où il impose la poursuite du lien contractuel contre la volonté exprimée de l'une, voire des deux parties.

1. Le contrôle judiciaire de la gravité de l'inexécution

Le refus de la résolution par le juge repose en premier lieu sur l'appréciation de la gravité de l'inexécution invoquée. Toutes les inexécutions contractuelles ne justifient pas nécessairement la disparition du contrat. Le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si l'inexécution alléguée présente un caractère suffisamment grave pour entraîner la résolution¹³⁹.

Lorsque l'inexécution est jugée mineure, temporaire ou susceptible d'être régularisée, le juge peut estimer que la résolution constitue une sanction disproportionnée. Il privilégie alors le maintien du contrat, éventuellement assorti de mesures correctrices telles que l'octroi de délais ou l'allocation de dommages et intérêts¹⁴⁰.

Cette appréciation traduit une évolution du droit des contrats vers une logique de proportionnalité des sanctions. La résolution, en tant que sanction radicale, n'est plus automatique ; elle devient conditionnée à une évaluation concrète des circonstances de l'espèce.

¹³⁷ Art 1092 du c.civ.g

¹³⁸ Art. 1103 et s., Code civil guinéen (résolution pour inexécution).

¹³⁹ Cass. civ., appréciation souveraine de la gravité de l'inexécution.

¹⁴⁰ F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil – Les obligations, Dalloz.

2. Le principe de conservation du contrat

Le refus de la résolution s'inscrit également dans le cadre plus général du principe de conservation du contrat. Selon ce principe, largement consacré par la doctrine et la jurisprudence, il convient de privilégier le maintien du contrat chaque fois que cela est possible, plutôt que son anéantissement¹⁴¹.

La conservation du contrat répond à des considérations à la fois économiques et juridiques. L'anéantissement du contrat peut entraîner des conséquences lourdes, non seulement pour les parties, mais également pour les tiers et pour l'économie générale des relations contractuelles. Le juge peut alors estimer que la poursuite du contrat, même imparfaitement exécuté, constitue la solution la plus équilibrée.

Dans cette perspective, le juge se voit reconnaître un rôle actif dans la stabilisation des relations contractuelles. Il ne se contente plus de sanctionner l'inexécution, mais cherche à préserver l'utilité sociale et économique du contrat.

3. Le refus de la résolution et l'imposition de solutions alternatives

Lorsque le juge refuse de prononcer la résolution, il peut accompagner ce refus de mesures destinées à rétablir l'équilibre contractuel. Il peut notamment ordonner l'exécution forcée du contrat, accorder des délais de paiement ou condamner la partie défaillante à des dommages et intérêts¹⁴².

Ces solutions alternatives permettent de concilier les intérêts des parties sans recourir à l'anéantissement du contrat. Elles illustrent le pouvoir d'adaptation du juge face aux difficultés d'exécution et renforcent son rôle de régulateur des relations contractuelles.

Dans certains cas, le juge peut également tenir compte du comportement des parties. Une partie de mauvaise foi, qui invoque une inexécution mineure dans le seul but de se soustraire à ses engagements, peut se voir opposer un refus de résolution. Cette approche participe d'une conception éthique du contrat, fondée sur l'exigence de loyauté dans l'exécution¹⁴³.

¹⁴¹ J. Carbonnier, *Droit civil – Les obligations*, PUF.

¹⁴² Art. 1110, *Code civil guinéen (pouvoirs du juge en matière de résolution)*.

¹⁴³ Art. 1035, *Code civil guinéen (exigence de bonne foi)*.

4. Le refus de la résolution comme limite à la liberté contractuelle

Le refus de la résolution constitue une atteinte manifeste à la liberté contractuelle. La partie créancière se voit privée de la faculté de mettre fin au contrat, tandis que la partie débitrice est contrainte de poursuivre l'exécution d'un engagement qu'elle a partiellement manqué.

Toutefois, cette atteinte apparaît justifiée par la nécessité de préserver l'équilibre contractuel et d'éviter des sanctions excessives. La liberté contractuelle ne saurait être invoquée pour justifier une rupture abusive ou disproportionnée du contrat¹⁴⁴.

Ainsi, à travers le refus de la résolution, le juge affirme une conception moderne du droit des contrats, dans laquelle la volonté des parties demeure essentielle, mais doit être conciliée avec des exigences supérieures de stabilité, de proportionnalité et de bonne foi.

¹⁴⁴ Ph. Malaurie, L. Aynès, *Les obligations*, LGDJ.

Section 2 : L'atteinte à la liberté contractuelle à travers la révision pour imprévision

Pour procéder à la révision le juge doit observer certaine condition (paragraphe 1) pour pouvoir appliquer son pouvoir (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Les conditions de révision pour imprévision

Pour que le juge procède la révision il faut une absence d'accord entre les parties(A) et à la demande d'une partie(B)

A- L'absence d'accord entre les parties

La révision du contrat pour imprévision constitue l'une des atteintes les plus significatives à la liberté contractuelle dans le droit contemporain des obligations. Elle permet au juge d'intervenir dans l'exécution du contrat afin d'en modifier les termes lorsque survient un bouleversement imprévisible des circonstances ayant rendu l'exécution excessivement onéreuse pour l'une des parties. Toutefois, cette intervention judiciaire ne saurait être automatique. Elle est strictement encadrée par des conditions préalables, au premier rang desquelles figure l'absence d'accord entre les parties¹⁴⁵.

En effet, le principe fondamental demeure celui de la primauté de la volonté contractuelle. Tant que les parties parviennent à s'entendre sur l'adaptation de leur contrat aux circonstances nouvelles, l'intervention du juge est exclue. La révision judiciaire ne constitue qu'un mécanisme subsidiaire, destiné à pallier l'échec de la renégociation conventionnelle¹⁴⁶.

1. La priorité donnée à la renégociation contractuelle

Le droit de l'imprévision repose sur une logique progressive. Avant toute intervention judiciaire, les parties sont invitées à tenter de renégocier leur contrat afin de rétablir l'équilibre rompu par le changement de circonstances. Cette exigence s'inscrit dans le prolongement du principe de bonne foi, qui gouverne l'exécution des contrats¹⁴⁷.

La doctrine souligne que la renégociation constitue l'expression la plus aboutie de la liberté contractuelle en situation de crise. Elle permet aux parties de conserver la maîtrise

¹⁴⁵ F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, *Droit civil – Les obligations*, Dalloz.

¹⁴⁶ Ph. Malaurie, L. Aynès, *Les obligations*, LGDJ.

¹⁴⁷ Art. 1035, *Code civil guinéen (bonne foi dans l'exécution du contrat)*.

de leur relation contractuelle, tout en adaptant les prestations aux réalités nouvelles¹⁴⁸. Dès lors, le juge ne peut se substituer aux parties tant qu'une solution négociée demeure possible.

L'absence d'accord entre les parties suppose donc que les tentatives de renégociation aient échoué ou se soient révélées impossibles. Cette condition vise à éviter une judiciarisation excessive des relations contractuelles et à préserver l'autonomie décisionnelle des cocontractants.

2. La caractérisation de l'échec de la renégociation

L'absence d'accord ne se présume pas. Il appartient à la partie qui sollicite la révision judiciaire de démontrer que les discussions engagées n'ont pas abouti. Cette preuve peut résulter de divers éléments, tels que le refus explicite de l'une des parties de renégocier, l'enlisement des négociations ou encore l'impossibilité manifeste de parvenir à un compromis acceptable¹⁴⁹.

Le juge apprécie souverainement la réalité de cet échec. Il peut tenir compte du comportement des parties, de leur diligence dans la conduite des discussions et de leur respect des exigences de loyauté et de coopération. Une partie qui refuserait systématiquement toute adaptation du contrat, sans motif légitime, pourrait se voir reprocher un manquement à la bonne foi¹⁵⁰.

Ainsi, l'absence d'accord entre les parties ne constitue pas seulement un constat factuel. Elle implique une appréciation qualitative des efforts de renégociation entrepris et du comportement adopté par chacun des cocontractants.

3. L'absence d'accord comme condition de légitimité de l'intervention judiciaire

L'exigence d'une absence d'accord préalable confère à la révision judiciaire pour imprévision un caractère exceptionnel. Le juge n'intervient qu'en dernier recours, lorsque

¹⁴⁸ J. Carbonnier, *Droit civil – Les obligations*, PUF.

¹⁴⁹ *Doctrine relative à la preuve de l'échec des renégociations en matière d'imprévision.*

¹⁵⁰ *Jurisprudence relative à l'exigence de loyauté dans la renégociation contractuelle.*

la liberté contractuelle n'a pas permis de surmonter la difficulté née du bouleversement des circonstances¹⁵¹.

Cette condition participe à la légitimité de l'atteinte portée à la liberté contractuelle. En effet, la révision judiciaire conduit le juge à modifier un contrat librement conclu, ce qui constitue une intrusion particulièrement forte dans la sphère contractuelle. Une telle intervention ne peut être admise que si les parties ont elles-mêmes échoué à rétablir l'équilibre contractuel.

En ce sens, l'absence d'accord entre les parties marque la frontière entre la liberté contractuelle et le pouvoir correcteur du juge. Elle traduit une conception équilibrée de l'imprévision, dans laquelle l'autonomie de la volonté demeure le principe, et l'intervention judiciaire, l'exception.

4. Une condition protectrice de la stabilité contractuelle

Enfin, l'exigence d'une absence d'accord préalable contribue à la stabilité des relations contractuelles. Elle évite que les parties ne saisissent trop rapidement le juge pour obtenir une modification judiciaire du contrat, au risque de fragiliser la sécurité juridique¹⁵².

En imposant une phase préalable de renégociation, le droit de l'imprévision favorise le dialogue contractuel et la recherche de solutions consensuelles. Ce n'est que lorsque cette voie s'avère infructueuse que le juge peut être appelé à intervenir pour préserver la continuité du contrat.

Ainsi, loin de remettre en cause la liberté contractuelle de manière systématique, la condition tenant à l'absence d'accord entre les parties en constitue, paradoxalement, une garantie. Elle assure que l'intervention judiciaire ne se substitue à la volonté des parties que lorsque celle-ci a atteint ses limites.

B- Une demande préalable

Outre l'absence d'accord entre les parties, la révision du contrat pour imprévision est subordonnée à une seconde condition essentielle : l'existence d'une demande préalable formulée par l'une des parties. Cette exigence procède d'une logique fondamentale du

¹⁵¹ Art. 1195, Code civil français (imprévision).

¹⁵² G. Cornu, *Introduction au droit*, Montchrestien.

droit des contrats, selon laquelle le juge ne peut intervenir que s'il est valablement saisi et sollicité par un cocontractant¹⁵³.

La révision judiciaire pour imprévision ne relève donc pas d'un pouvoir d'office du juge. Elle suppose une initiative claire et explicite de la partie qui se prétend lésée par le bouleversement imprévisible des circonstances. Cette condition marque une limite importante à l'ingérence judiciaire dans la sphère contractuelle.

1. La demande préalable comme manifestation de la volonté de poursuivre le contrat

La demande préalable ne vise pas à obtenir la disparition du contrat, mais au contraire à en assurer la poursuite dans des conditions rééquilibrées. En sollicitant la révision judiciaire, la partie concernée manifeste sa volonté de maintenir le lien contractuel malgré les difficultés rencontrées¹⁵⁴.

Cette précision revêt une importance particulière. Contrairement à la résolution ou à l'annulation, la révision pour imprévision s'inscrit dans une logique de conservation du contrat. La demande préalable traduit ainsi une adhésion, au moins partielle, à la philosophie du maintien contractuel, même lorsque l'exécution est devenue excessivement onéreuse.

Le juge ne saurait donc imposer une révision contre la volonté des parties. L'intervention judiciaire n'est légitime que si l'une d'elles exprime clairement le souhait d'adapter le contrat plutôt que d'y mettre fin.

2. Le contenu et la portée de la demande préalable

La demande préalable doit être suffisamment précise pour permettre au juge d'apprécier la réalité de la situation d'imprévision. Elle doit exposer les circonstances nouvelles invoquées, leur caractère imprévisible au moment de la conclusion du contrat, ainsi que les conséquences économiques ou juridiques qui en résultent pour la partie demanderesse¹⁵⁵.

¹⁵³ G. Cornu, *Introduction au droit*, Montchrestien.

¹⁵⁴ Ph. Malaurie, L. Aynès, *Les obligations*, LGDJ.

¹⁵⁵ F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, *Droit civil – Les obligations*, Dalloz.

Il ne s'agit pas d'une simple protestation ou d'une réserve vague. La doctrine souligne que la demande doit révéler une réelle volonté d'obtenir une adaptation du contrat, et non une remise en cause déguisée de l'engagement contractuel¹⁵⁶. À défaut, le juge pourrait considérer que la condition de la demande préalable n'est pas remplie.

En outre, cette demande doit intervenir après l'échec des tentatives de renégociation. Une saisine prématurée du juge, sans effort sérieux de dialogue contractuel, serait contraire à l'esprit même de l'imprévision et pourrait conduire au rejet de la demande.

3. La demande préalable comme garantie du caractère exceptionnel de la révision judiciaire

L'exigence d'une demande préalable contribue à préserver le caractère exceptionnel de la révision judiciaire pour imprévision. Elle empêche le juge d'intervenir de manière systématique ou automatique dès lors qu'un déséquilibre contractuel apparaît¹⁵⁷.

Cette condition permet également d'éviter une instrumentalisation de l'imprévision par des parties cherchant à se soustraire à leurs engagements pour des motifs opportunistes. En imposant une démarche active et argumentée, le droit de l'imprévision limite les risques d'abus et renforce la sécurité juridique des relations contractuelles.

Le juge conserve ainsi une position d'arbitre, et non d'acteur principal de l'adaptation contractuelle. Son rôle consiste à intervenir en dernier recours, lorsque la volonté des parties, exprimée à travers la renégociation, a montré ses limites.

4. Une condition respectueuse de la liberté contractuelle

Paradoxalement, l'exigence d'une demande préalable contribue à la protection de la liberté contractuelle. En subordonnant la révision judiciaire à l'initiative d'une partie, le droit évite que le juge ne modifie d'office un contrat librement conclu¹⁵⁸.

La liberté contractuelle demeure ainsi le principe directeur. La révision judiciaire ne s'impose que lorsque cette liberté ne permet plus de faire face à des circonstances

¹⁵⁶ J. Carbonnier, *Droit civil – Les obligations*, PUF.

¹⁵⁷ Doctrine relative au caractère exceptionnel de la révision judiciaire pour imprévision.

¹⁵⁸ Art. 1195, *Code civil français (initiative de la partie)*.

exceptionnelles et imprévisibles. La demande préalable marque alors le point de bascule entre l'autonomie de la volonté et l'intervention corrective du juge.

En définitive, la condition tenant à la demande préalable confirme que la révision pour imprévision ne constitue pas une remise en cause générale du principe de force obligatoire du contrat. Elle s'inscrit dans un cadre strict, destiné à concilier la stabilité contractuelle avec les exigences d'équité et de justice dans l'exécution des engagements.

Paragraphe 2 : Le pouvoir du juge dans la révision

Lorsque les conditions de la révision pour imprévision sont réunies, et notamment en cas d'échec de la renégociation et à la suite d'une demande préalable d'une partie, le juge se voit reconnaître un pouvoir d'intervention particulièrement étendu dans l'exécution du contrat. Cette prérogative constitue l'une des atteintes les plus significatives à la liberté contractuelle, dans la mesure où elle autorise le juge à modifier un contrat librement conclu afin d'en assurer la poursuite¹⁵⁹.

Ce pouvoir ne s'exerce toutefois pas de manière discrétionnaire. Il est encadré par la loi et par la jurisprudence, lesquelles définissent les formes et les limites de l'intervention judiciaire en matière de révision contractuelle.

1. Le pouvoir d'adaptation du contrat par le juge

La première manifestation du pouvoir du juge en matière de révision pour imprévision réside dans sa faculté d'adapter le contrat. Cette adaptation peut consister en une modification des conditions financières, des modalités d'exécution ou encore de la répartition des charges contractuelles¹⁶⁰.

L'objectif poursuivi est le rétablissement de l'équilibre contractuel rompu par le changement imprévisible de circonstances. Le juge ne cherche pas à substituer sa propre volonté à celle des parties, mais à rapprocher le contrat de ce qu'il aurait été si les circonstances nouvelles avaient été envisagées lors de sa conclusion¹⁶¹.

Cette adaptation judiciaire peut prendre des formes diverses. Le juge peut, par exemple, réviser le prix, accorder des délais supplémentaires, modifier les quantités ou ajuster

¹⁵⁹ F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, *Droit civil – Les obligations*, Dalloz.

¹⁶⁰ Ph. Malaurie, L. Aynès, *Les obligations*, LGDJ.

¹⁶¹ J. Carbonnier, *Droit civil – Les obligations*, PUF.

certaines obligations accessoires. Ces mesures traduisent une intervention ciblée, destinée à rendre l'exécution du contrat à nouveau supportable pour la partie lésée.

2. La fixation des nouvelles conditions contractuelles

Dans l'exercice de son pouvoir de révision, le juge peut être amené à fixer de nouvelles conditions contractuelles applicables aux parties. Cette faculté constitue une ingérence particulièrement forte dans la sphère contractuelle, puisqu'elle revient à imposer un contenu contractuel que les parties n'ont pas expressément négocié¹⁶².

Toutefois, cette intervention se justifie par l'échec des mécanismes conventionnels d'adaptation. Le juge agit alors comme un arbitre chargé de déterminer une solution équilibrée, en tenant compte des intérêts respectifs des parties et de l'économie générale du contrat.

La doctrine souligne que cette fixation judiciaire des conditions contractuelles doit demeurer proportionnée et raisonnable. Le juge ne saurait procéder à une refonte complète du contrat, mais seulement à des ajustements nécessaires pour permettre la poursuite de la relation contractuelle¹⁶³.

3. Le pouvoir de mettre fin au contrat en cas d'impossibilité de révision

Lorsque l'adaptation du contrat apparaît impossible ou insuffisante pour rétablir l'équilibre contractuel, le juge peut être conduit à mettre fin au contrat. Cette faculté constitue une alternative à la révision, destinée à éviter la poursuite d'un contrat devenu manifestement inéquitable ou économiquement insoutenable¹⁶⁴.

La résiliation ou la résolution judiciaire du contrat intervient alors comme un ultime recours. Elle permet de préserver les intérêts des parties lorsque toute tentative d'adaptation se révèle vaine. Dans ce cas, le juge détermine les conditions de la fin du contrat, notamment en ce qui concerne les restitutions éventuelles et l'indemnisation des préjudices subis.

¹⁶² Doctrine relative au pouvoir de fixation judiciaire du contenu contractuel.

¹⁶³ Jurisprudence relative aux limites de la révision judiciaire.

¹⁶⁴ Art. 1195, Code civil français (pouvoirs du juge en matière d'imprévision).

Cette possibilité souligne que le pouvoir du juge en matière d'imprévision ne se limite pas à la conservation du contrat à tout prix. Il s'agit d'un pouvoir équilibré, visant à concilier la poursuite de la relation contractuelle avec la protection des parties contre des charges excessives.

4. Les limites du pouvoir judiciaire dans la révision pour imprévision

Bien que le pouvoir du juge en matière de révision pour imprévision soit étendu, il demeure encadré par des limites strictes. En premier lieu, le juge doit respecter l'économie générale du contrat. Il ne peut en modifier la nature ni en altérer les éléments essentiels¹⁶⁵.

En second lieu, l'intervention judiciaire doit être guidée par les principes de proportionnalité et de bonne foi. Le juge veille à ce que la révision ne crée pas un déséquilibre inverse, au détriment de l'autre partie. Il s'efforce ainsi de préserver un équilibre global conforme aux exigences de justice contractuelle¹⁶⁶.

Enfin, le juge ne peut intervenir qu'en présence de circonstances répondant strictement aux critères de l'imprévision. À défaut, toute modification judiciaire du contrat constituerait une remise en cause injustifiée de la force obligatoire des conventions.

5. Une consécration du rôle régulateur du juge

Le pouvoir reconnu au juge dans la révision pour imprévision consacre pleinement son rôle de régulateur des relations contractuelles. Loin de se limiter à une application mécanique des règles, le juge intervient pour adapter le contrat aux réalités économiques et sociales contemporaines.

Cette évolution traduit une conception renouvelée de la liberté contractuelle. Celle-ci demeure un principe fondamental, mais elle s'inscrit désormais dans un cadre normatif plus large, au sein duquel l'équité, la bonne foi et la stabilité des relations contractuelles occupent une place centrale¹⁶⁷.

¹⁶⁵ G. Cornu, *Introduction au droit*, Montchrestien.

¹⁶⁶ Art. 1035, *Code civil guinéen* (bonne foi dans l'exécution du contrat).

¹⁶⁷ Doctrine relative à la fonction régulatrice du juge en droit des contrats.

LES LIMITES A LA LIBERTE CONTRACTUELLE

Ainsi, à travers la révision pour imprévision, le juge participe activement à la modernisation du droit des contrats, en conciliant la force obligatoire du contrat avec la nécessité d'en assurer une exécution juste et équilibrée.

CONCLUSION GENERALE

La liberté contractuelle occupe une place centrale dans le droit des obligations. Héritée de la théorie classique de l'autonomie de la volonté, elle consacre la faculté pour les parties de conclure librement un contrat, d'en déterminer le contenu et d'en organiser l'exécution. Longtemps perçue comme un principe quasi absolu, elle apparaît toutefois, à l'issue de cette étude, comme une liberté encadrée, progressivement façonnée par l'intervention du juge.

L'analyse menée dans ce mémoire a permis de mettre en évidence que les atteintes à la liberté contractuelle ne résultent pas uniquement de la loi, mais également de l'action juridictionnelle. Le juge intervient d'abord lors de la formation du contrat, à travers son pouvoir d'interprétation. En recherchant le sens véritable des stipulations contractuelles, il peut dépasser la lettre du contrat pour en dégager la portée réelle, en recourant tantôt à une interprétation subjective, tantôt à une interprétation objective, ou encore à la méthode *in favorem*. Ce pouvoir interprétatif, s'il vise à clarifier la volonté des parties, peut également conduire à l'émergence d'obligations implicites, traduisant ainsi une première limitation de l'autonomie contractuelle.

Le juge dispose ensuite d'un pouvoir déterminant en matière de qualification et de requalification du contrat. En restituant aux faits leur véritable nature juridique, il peut soit majorer les obligations contractuelles en soumettant l'acte à un régime plus contraignant, soit réduire la portée juridique de certaines stipulations excessives. Cette faculté illustre clairement que la qualification contractuelle ne relève pas de la seule volonté des parties, mais constitue une prérogative essentielle du juge, exercée dans un souci de protection de l'ordre public et de rééquilibrage des relations contractuelles.

L'étude a également montré que l'intervention judiciaire ne se limite pas à la formation du contrat. Lors de son exécution, le juge peut aller jusqu'à maintenir le contrat, même lorsque celui-ci est susceptible d'annulation ou de résolution. En refusant l'anéantissement du contrat, le juge privilégie la stabilité des relations contractuelles et la préservation d'intérêts jugés supérieurs, au détriment de la liberté des parties de mettre fin à leur engagement. Cette logique de conservation du contrat se manifeste de manière particulièrement significative à travers le mécanisme de la révision pour imprévision. Face à un bouleversement imprévisible des circonstances, le juge peut adapter le contrat,

en fixer de nouvelles conditions ou, en dernier recours, y mettre fin, afin d'éviter une exécution devenue excessivement onéreuse.

Il ressort de cette recherche que la liberté contractuelle, bien qu'elle demeure un principe fondamental, n'est plus conçue comme une liberté souveraine. Elle s'inscrit désormais dans un cadre normatif élargi, au sein duquel le juge joue un rôle central de régulation. Cette évolution traduit une transformation profonde du droit des contrats, orientée vers une conciliation entre l'autonomie de la volonté, les exigences d'équité, la protection de la partie faible et la sécurité juridique.

En définitive, loin de signifier le déclin de la liberté contractuelle, l'intervention du juge en révèle plutôt une redéfinition. La liberté de contracter subsiste, mais elle est encadrée par un contrôle judiciaire destiné à garantir un équilibre contractuel conforme aux valeurs contemporaines du droit. Le juge apparaît ainsi non comme un adversaire de la liberté contractuelle, mais comme son régulateur, chargé d'en assurer un exercice juste, raisonnable et conforme à l'intérêt général.

TABLE DES MATIERES

LISTE DES ABREVIATIONS	i
RESUME.....	ii
ABSTRACT	iii
SOMMAIRE.....	iv
INTRODUCTION.....	1
PARTIE 1: L'ENCADREMENT LEGISLATIF DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE	5
Chapitre I : Les atteintes conventionnelles à la liberté contractuelle.....	7
Section 1 : Les clauses limitant la liberté de contracter ou de ne pas contracter	7
Paragraphe 1 : La clause de non concurrence.....	7
A- Le régime juridique de la clause de non-concurrence	8
B- La clause de non-concurrence face à la liberté contractuelle.....	9
Paragraphe 2 : La clause de non-convol	11
A- Clause de célibat	11
B- Clause de viduité	12
Section 2 : Les clauses limitant la liberté de choisir son cocontractant, le contenu et la forme du contrat.....	14
Paragraphe 1 : Le pacte de préférence et la promesse unilatérale :.....	14
A- Le pacte de préférence	14
B- Promesse unilatérale	16
Paragraphe 2 : Le contrat d'adhésion et le droit de rémption.....	17
A- Contrat d'adhésion :	17
B- Le droit de rémption :.....	17
Chapitre II : Les disposition d'ordre public et la liberté contractuelle	19
Section 1 : L'ordre public, une limite à la liberté contractuelle.....	19
Paragraphe 1 : Une précision sémantique de la notion d'ordre public :	19
A- Ordre publique de direction.....	19
B- L'ordre public de protection	20
Paragraphe 2 : La liberté contractuelle et l'ordre public, une conciliation légitime :	22
Section 2 : La sanction découlant de la violation des dispositions d'ordre public	23
Paragraphe 1 : La nullité.....	23
A- Précision sémantique de la notion de nullité.....	23
B- Le régime juridique de la nullité.....	23
Paragraphe 2 : Les autres sanctions.....	26

A- La caducité.....	26
B- La résolution du contrat	27
PARTIE 2: L'ENCADREMENT DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE INITIE PAR LE JUGE.....	30
Chapitre I : L'encadrement à la liberté contractuelle initié par le juge lors de la formation du contrat.....	32
Section 1 : Atteintes à travers le pouvoir interprétatif du juge.....	32
Paragraphe 1 : Les méthodes interprétatives	32
A- La méthode objective ou subjective	32
B- La méthode in favorem	35
Paragraphe 2 : La naissance des nouveaux devoirs découlant de l'interprétation .	39
Section 2 : Atteintes à travers le pouvoir de qualification et requalification par le juge	40
Paragraphe 1 : Les types de qualification et requalification.....	40
A- La requalification par majoration	40
B- La requalification par réduction.....	43
Paragraphe 2 : Le sort du contrat découlant de la qualification ou requalification	46
Chapitre II : Les atteintes à la liberté contractuelle liées au maintien du contrat par le juge	49
Section 1 : Le maintien d'un contrat susceptible d'être anéanti.....	49
Paragraphe 1 : Le maintien d'un contrat annulable par le juge	49
Paragraphe 2 : le refus de la résolution par le juge	53
Section 2 : L'atteinte à la liberté contractuelle à travers la révision pour imprévision	56
Paragraphe 1 : Les conditions de révision pour imprévision	56
A- L'absence d'accord entre les parties	56
B- Une demande préalable	58
Paragraphe 2 : Le pouvoir du juge dans la révision	61
CONCLUSION GENERALE	65